

CM Droit civil : Les contrats spéciaux

QCM en examen du partiel

INTRODUCTION

§ 1 – Définitions

Article 1105 du code civil : il y' a des contrats qui obéissent aux règles générales (à priori tous) et il y' a des contrats qui obéissent à des règles spéciales.

L'article 1105 nous dit que le contrats est soumis à des règles générales qui sont soumis.

La distinction règle commune / générale / spéciale est ce qui va nous intéresser.

L'expression contrat spéciaux est un faux ami, les contrats spéciaux il y' en a pas, ils le sont tous précisément. Le contrat général n'existe pas.

Chaque contrat a sa particularité et chaque contrats est spécial. On devrait continuer de parler de droit commun de contrat et droit spécial de contrat.

Ce que donne le code civil ce sont des règles particulières à des contrats spéciaux, qui donne une série de catégorie avec des contrats nommés et en nommant les contrats qui sont listés dans le code civil le législateur donne à ces contrats des règles spéciales.

Alors que les règles de droit commun ont vocation à s'appliquer à tout les types de contrat sans distinction et les règles spéciales n'ont vocation à s'appliquer qu'à certains types de contrats.

Nous allons étudier l'ensemble des règles spéciales applicable à un certain grand nombre de contrats et dans un domaine spécial.

§ 2 – L'opération de qualification

Nous avons affaire à des contrats spécifiques, qui ont des règles spéciales qui leur sont applicable en les reconnaissant et les désigner, c'est-à-dire à ce contrat là qu'on doit appliquer une règle spéciale en plus.

Pour désigner le bon contrat, il faut qualifier. On va enfermer le réel dans des catégories.

Les juristes ont des outils intellectuels qui enferment le réel (les biens meubles/ immeubles, les bien physiques/morales ..)

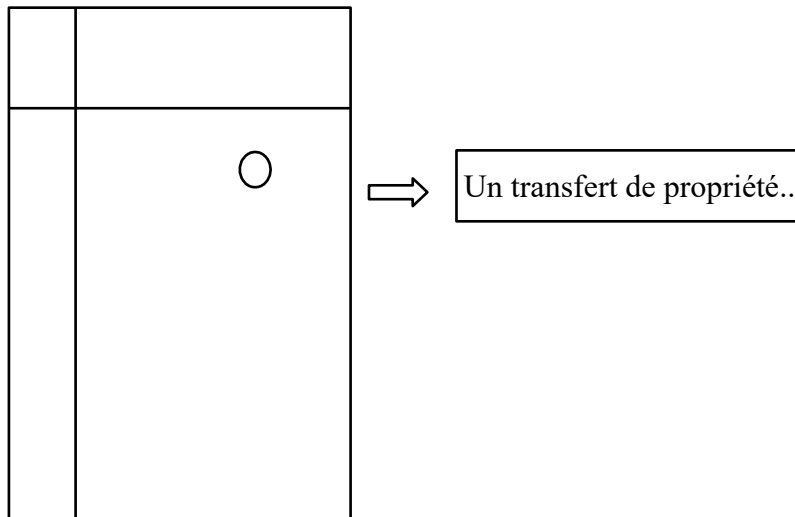
Il est alors important de les ranger dans la bonne case, il est important de les ranger dans des catégories et pourvoir lui appliquer les règles propre à la catégorie.

Comment je reconnaît que c'est une chose et pas une personne ? C'est quoi qui me permet de qualifier ?

Il faut que chaque catégorie soit accompagnée de sa définition. Parce qu'une définition c'est un outil de mémorisation, parce que dans la définition il y' a en quelque mots les critères de reconnaissance de la catégorie dont on parle.

Ce qui caractérise la catégorie, ce qui fait l'essence de la catégorie et on va le mettre dans cette

définition.



Quelles sont les règles qui s'appliquent à un contrat hors genre ?

Seules les règles de droit commun s'appliquent aux contrats hors catégories.

Le droit spécial c'est une série de contrat qui s'appliquent à une série particulière de droit spécial. Apprendre par cœur des classifications (vente, dépôt, mandat..)

Le contrat nommé > qui est connu de la loi et le législateur lui donne un nom (le contrat de crédit bail par exemple)

le contrat innommé > qui n'est pas connu de la loi et c'est peut être la jp qui commence à la construire

Le critère qui va être décisif est souvent appelé **l'obligation essentielle/ fondamentale/ caractéristique** (ce n'est jamais l'obligation au prix) c'est ce qui va déclencher la qualification. On va insister sur cette obligation caractéristique et c'est ce qui va déclencher la qualification du contrat

Parfois nous allons être confrontées à des contrats complexes (contrats hybrides, l'ingénierie contractuelle, montage..), **le principe de la liberté contractuelle** les parties font ce qu'ils veulent. Et l'analyste a devant lui des éléments caractéristiques qui permettent de le ranger à la fois dans la vente, le bail et le prêt.

Devant ces hybrides il y' a plusieurs façons de faire, on peut pas exemple avoir une première approche qui consiste à dire que je vais essayer de repérer l'obligation la plus importante parmi toute les obligations caractéristiques et qui va aplatis tout ce qui accessoire et donc moins important.

Par exemple le contrat de déménagement, parce qu'on a du transport, de la manutention, des obligations de sécurité, des services, de la douane, de mandat. Quel type de contrat est ce dans ce cas ? Généralement c'est que c'est un contrat d'entreprise.

On peut faire différemment et appliquer une qualification mixte au lieu d'unique, cad qu'elle va tenir compte de l'hybridation et v=on va dire que le contrat se décompose dans le temps et on va appliquer des qualifications successives (contrat de service, puis de transport, puis de vente...) et on va respecter chaque portion du contrat.

On peut également distribuer les différentes parties (**qualification distributive**).

Face à ces hybrides on a trois manières d'agir :

- **une qualification unique**
- **une qualification mixte successive**
- **une qualification mixte distributive**

§ 3 – Domaine et sources du droit spécial des contrats

Il est quasiment impossible de parler du domaine sans les sources.

Le domaine :

Le domaine du droit spécial des contrats est assez difficile à délimiter.
Pourquoi les législateurs ont pris un domaine pour le délimiter ensuite ?

A l'époque de **1804** on a 80% de la population qui n'est pas alphabétisée, on prévoit de créer un outil écrit et on entre dans la période de codification ;

On va prendre les contrats de la vie de tout jours, usuels et de la vie de analphabètes et mettre à plat un régime juridique pour chacun de ces contrats de la vie usuel. Mais on va pas obliger toute la population à suivre ces règles au prétexte que 80% de la population ne sont pas capable de lire et de comprendre, il faut aussi penser à ceux qui savent lire et comprendre.

C'était aux parties de faire leur contrat et le principe de liberté contractuelle existait déjà.

Le **supplétif**, c'est le contraire de l'impératif et qui vient suppléer le silence des parties, étant précisée que par supposition ceux qui ne savent pas lire ni écrire vont passer à coté de cas que le code civil soulève, ils vont pouvoir compter en cas de besoin sur le code civil qui va venir suppléer leur silence.

La question est traité dans le code civil et sa solution est supplétive, pour venir suppléer le silence des parties. Mais si les parties ont prévu cela on a pas besoin du code et on applique le contrat (la volonté des parties).

La suppléité laisse des libertés aux parties, car si elles gardent le silence c'est la règle du code civil qui va s'appliquer.

Ce sont pas des contrats spéciaux, mais les contrats les plus usuels, quand on parle de contrat spécial des contrats on vise à première vue les règles prévues dans le code civil.

Parmi tout ces contrats il faut désormais faire une sélection, on a le contrat de travail par exemple, il était usuel et il est toujours usuel mais peu à peu il devient très spécial, ou encore le contrat de mariage qui pour le coup est vraiment spécial (notion de couple, mariage, divorce, succession..)

On écarte les contrats les plus spéciaux et il y' a d'autres contrats qui sont traités dans le code civil, par exemple le contrat des sociétés qui est sorti du domaine du droit spécial des contrats, pour faire partie du droit du commerce.

Il y' a des contrats qui se sont segmentées, alors que d'autres ont été délaissées par la pratique jusqu'au jour ou ils ont repris de la vigueur tandis que d'autres sont tombés dans l'oubli.

Lorsqu'ils sont plus utilisés le législateur à tendance à créer des règles.

Au tout départ en **1804** on avait la vente ou l'entreprise (des contrats payants, contrats d'affaires) qui étaient des grands contrats, et à coté on avait le prêt, le dépôt, le mandat et la transaction (des contrats d'amis, gratuits c'était des contrats humaines et pas d'affaires) qui sont eux peu utilisés.

Ce classement a été totalement bousculé aujourd'hui on a des mandataires professionnels et une grande partie de l'activité commerciale est traitée avec le contrat de mandat. C'est devenu un contrat professionnel et payant et extrêmement répandu, par exemple le prêt, le dépôt. Des contrats devenus onéreux et qui ont perdu leur caractère d'amis.

Par exemple, on a pas dans le code civil le contrat d'assurance alors qu'aujourd'hui beaucoup de contrats d'assurances sont obligatoires (véhicule, maison, travail...)

On a des contrats qui se sont transformés avec les époques.

Tout ceux nouveaux qui sont en réalité des contrats d'affaires, dont le prêt, la franchise, le crédit bail, le sponsoring, le parking.

Les sources :

Au départ en **1804**, les sources c'est le code civil. C'est pas parce qu'on est une règle spéciale qu'on se voit pas appliquer le droit commun. Parfois la règle spéciale écarte une partie du droit commun, que ce qui est incohérent avec la juridiction.

Elles sont supplétives au départ, on a un principe qui s'est appliqué dès l'origine en 1804, petit à petit aujourd'hui les sources du droit spécial des contrats ne sont plus QUE dans le code civil il y'en a dans d'autres codes (dans les lois spéciales, par exemple.)

Donc c'est difficile de se contenter d'utiliser que le code civil, par exemple la vente (code civil, code civil spécial, les autres sources du droit de la vente).

Mais le code civil reste quand même la source (pas en volume), mais en hiérarchie ça reste la source principale. Le droit spécial des contrats c'est aussi un droit qui concerne une institution juridique qui est laissée à une grande liberté des parties.

Une des sources première du droit des contrats c'est la volonté des parties et ce qu'ils ont prévu compte beaucoup. Aujourd'hui dans le code civil et surtout dans les autres codes et lois on a des règles plutôt impératif et il faut contrôler la volonté des parties (dans un espace d'impérativité ou non)

Sa conformité doit être encore plus contrôlée aujourd'hui, puis il y'a la jurisprudence. La plupart des articles n'ont pas été modifiés depuis 1804. La jurisprudence devait préciser maintes fois des règles qui ne sont pas précisées dans le code, et c'est le juge qui le précise.

Il faut coordonner une disposition de droit commun et une disposition de droit spécial.

Puis nous avons les éventuels coutumes, par exemple les habitudes des marchands on les prend en compte pour suppléer un éventuel silence des parties.

Aujourd'hui on est confronté à une multiplication, d'hyper spécialisation des contrats spéciaux. Par exemple le contrat des associations, la concession immobilière, la sous-traitance, la location actions matières immobilières, les mandats d'agents immobiliers...sont toutes des contrats qui ne sont pas présentes dans le code civil.

Nous avons les codes d'autres codes de contrats qui sont traités en dehors du code civil, par exemple le code d'assurance, le bail commercial, la construction d'habitation, le crédit immobilier, le dépôt hospitalier...

Nous allons traiter des contrats qui sont à la fois les plus usuels, les plus utilisés et qui font l'objet le plus d'hyper spécialisation. Cela agace et rend la matière très compliquée, d'autant plus que la philosophie de **1804** était une philosophie qui était très efficace.

Beaucoup de spécialistes ont réfléchi à une réforme, Est ce qu'on ne pourrait pas transformer le code civil pour mettre dans le code civil des règles de coordination par exemple, est ce qu'on ne pourrait pas intégrer les règles jurisprudentielles dans le code civil.

Ils ont fait des propositions, il y a beaucoup de propositions sur le fait de reconstituer le code civil. **L'association Henry Capitan en 2017** et qui a fait l'objet d'une **deuxième réforme en 2020**, le législateur n'en a pas tenu compte.

Le ministère de la justice va commander le rapport, et ont réfléchi sur un projet de recodification et ils l'ont présenté après la période de Covid et il ne s'est pas passé grand chose, La réforme elle est prête mais on attend une réponse.

Il y a d'autres auteurs qui ont proposés des choses radicales (par exemple **Alan Benaban**, qui considère qu'il faut arrêter de faire référence à la nature du contrat et que ce qui est important n'est pas la nature du contrat mais les obligations et qu'il faut traiter les contrats obligation par obligation)

Si l'on fait une réforme du droit spécial des contrats on ne peut plus ignorer **le droit international** (le **droit international public**, le **droit international privé** qui traite de deux grandes questions essentielles: Quelle est la règle qui s'applique entre deux règles de nationalités différentes « le conflit des lois », Quel juge sera compétent « le conflit juridique ») , **de l'UE** (qui régit certains nombres de contrats souvent les plus usuels, qui se repose sur la protection des consommateurs).

Puis il y a un autre point celui des droits de l'homme, les contrats posent des questions de droit fondamentaux. L'exemple type est le bail avec la question de la religion qui est un droit fondamental.

C'est une question où on met en confrontation des règles de droit usuel et des principes fondamentaux et il faut bien les coordonner.

§ 4 – Les caractères du droit spécial des contrats

On est passés aujourd'hui au supplétif à l'impératif. Le législateur prends que des textes impératif à présent.

Aujourd'hui nous avons la plus grande masse des règles qui s'appliquent aux contrats dit spéciaux qui sont impératif, nous avons toujours les règles du code civil, mais à force d'hyper spécialisé les contrats elles se sont écarter par des règles encore plus spéciales.

On a un phénomène d'hyper spécialisation des contrats avec deux types :

- **l'hyper spécialisation objectif**, on va prendre en compte l'objet des contrats pour en faire des sous catégories (vente mobilière ou immobilière, immeubles d'habitation ou de non habitation, distinguer les zones)
- **l'hyper spécialisation subjectif**, qui elle tient aux qualités de l'un ou des deux contractants (professionnels ou non professionnels, consommateur ou le professionnel)

Cette hyper spécialisation entraîne la complexification (catégories, sous- catégories...). Il faut s'intéresser à la volonté des parties, au genre commun, les règles particulières de cette sous catégorie..Le droit commune st la théorie généraliser du droit des contrats

C'est la raison pour laquelle la recodification correspond à une simplification car c'est inexplicable. On va se focaliser uniquement sur le code civil (quasiment pas d'arrêts) et en mettant en avant l'aspect pratique de la matière qui obéis à la logique des contrats.

Quand des parties concluent un contrat elles ont un objectif économique, elles font ça parce qu'elles ont un objectif pratique. La science du juriste c'est d'offrir aux parties le contrat qui correspondra le mieux à l'objectif fixé par les parties.

4 GRANDS PARTIES DU COURS :

Les contrats relatifs aux biens

Les contrats relatifs aux services

Les contrats relatifs aux aléas

Les contrats relatifs aux litiges

PREMIÈRE PARTIE – LES CONTRATS RELATIFS AUX BIENS

TITRE I – LES CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ

La vente est l'exemple type de contrat translatif de propriété, c'est le contrat le plus usuel.

CHAPITRE 1 – LE CONTRAT DE VENTE

La vente c'est le modèle de tout les autres contrats.

Section 1 – Définition et qualification de la vente

La vente de la vente est donné dans le code civil par **l'article 1582 alinéa 1**. Cette définition est très approximatif car elle ne donne absolument pas les éléments de reconnaissance du contrat de vente, or c'est à cela que doit servir une définition (qui sers à qualifier et reconnaître).

L'article 1583 nous permet de réfléchir à ce qui fait les éléments essentiels du contrat de vente :

- Les parties ait convenue d'**un transfert de propriété**
- qui doit porter sur **un bien**/ une chose
- en contrepartie d'**un prix**

Un contrat par lequel la propriété d'un bien est transféré en contrepartie d'une somme d'argent dénommé prix.

Des éléments qui nous permettent de qualifier la vente (un contrat synallagmatique, un contrat payant, conutatif...). Pour la vente on parle d'acheteur ou d'acheteuse (venderesse/ vendeur)

Il existe des liens corporels qu'on touche et puis il y' a les liens incorporels par exemple une action en société ne se touche pas. Quand on parle de vente à bien corporel, on parle pas de vente car ça doit être précis. On parle alors de cession (de droit d'auteur, de commerce..)

Ça nous permet de reconnaître le contrat de vente et de distinguer ce contrat des autres contrats :

- Il faut **un bien**, ce qui est au cœur du contrat de vente c'est un bien (une chose) ce qui fait la différence avec les contrats où il n'y a pas de chose dans le cœur du contrat (le contrat d'entreprise par exemple ou l'action, le service, le comportement de son co-contractant compte plus)
- le **transfert de propriété**, va nous permettre de faire la différence avec les contrats où il n'y a pas de transfert de propriété (le bail par exemple, dans ces cas là une personne n'avait pas l'appartement et le bien faudra qu'il le laisse à un moment donc à la fin il y' a une obligation de restitution, dans que le bail est en cours les parties sont en relation) dans la vente il y' a un aspect définitif du contrat.

Il y' a des contrats de vente où il y' a une obligation de restitution et qui ne se fait pas par le bien, cela se fait pas équivalent c'est-à-dire que ce n'est pas le même bien qui est requis.

Par exemple la concession d'une carrière qu'on loue à quelqu'un mais ce quelqu'un a le droit de creuser sur ses terres pour extraire des minéraux..dans ce cas là c'est à la fois un bail sur le terrain et d'une certaine manière un transfert de propriété sur les produits du terrain. C'est un bail pour ce qu'il reste et c'est de la vente pour ce qui a été enlevé.

Ou encore, le dépôt vente c'est une technique de distribution commerciale (vente de vêtements, de journaux, friperie..), ce n'est pas un dépôt (à la fin on restitue exactement la même chose alors qu'ici il ne peut pas y avoir restitution si la vente est faite), mais cela est considéré comme un **mandat** ou encore une **vente conditionnelle** (vente sous conditions suspensives de revente, le fournisseur vend à son commerçant sous condition, c'est une vente sans transfert de propriété)

- Le **prix**, à chaque fois qu'on parlera de prix on parlera de somme d'argent, un prix c'est une somme d'argent nécessairement. Cela permet de faire la différence avec une série de contrats : par exemple, la donation ou le don où il n'y a pas de prix. Mais parfois il y' a des donations avec charge. Tout dépend du coût et de la valeur de la contrepartie. S'il n'y a pas du tout d'équivalence cela restera une donation mais avec charge.

L'échange, il n'y a pas de prix donc pas d'échange. Pour que l'échange soit égalitaire on va faire un complément (la soulte), si la soulte est inférieure à la valeur du bien on va appliquer l'accessoire principal donc cela reste un échange. En revanche si la somme d'argent est supérieure à la valeur de l'argent, donc c'est une vente avec un prix et un accessoire en nature.

Faire la différence entre une vente et un apport de société (propriétaire d'une voiture et la société devient le nouveau propriétaire) en contrepartie on reçoit une valeur (un titre, une part sociale) ce n'est pas un prix donc pas une vente.

Un contrat où il est prévu qu'il ait un prix à payer et au moment de payer l'acheteur n'a pas la somme d'argent mais il a un bien d'une valeur à peu près équivalente, le vendeur peut accepter. Alors cela est considéré comme une vente, le paiement du prix se fait par la dation en paiement. Ce qui compte c'est que le prix était prévu à l'origine du contrat et au moment de payer le prix devient une valeur d'un bien.

La vente fait l'objet d'**hyper spécialisation et d'impérativité**, dans le code civil les règles générales n'ont pas bougé et on a des ventes mobilières/ immobilières, des ventes aux enchères, électroniques.. on a tout un tas de catégories hyper spécial à l'intérieur de la vente.

Section 2 – Formation de la vente

Ce qui faut retenir c'est que la vente est soumise aux règles de droit commun c'est pas anormal, les règles de droit commun ont été pensés avec l'exemple de la vente donc cela marche plutôt bien.

Néanmoins il existe quelques règles spéciales qu'on ne peut pas ignorer, avec tout un tas de préparation de contrat de vente et l'échange de consentement.

Quelques règles spéciales doivent être mis en avant pour comprendre comment se forment la plupart des contrats de vente ?

§ 1 – La préparation du contrat de vente

A – Les ventes à l'agrée

Il faut mettre de côté l'image un peu enfantine qui a été véhiculé par les rédacteurs du code civil. Qui ont considérés qu'un contrat se formait par la rencontre d'offre et d'acceptation.

La réalité du quotidien des contrats n'est pas forcément de cette manière là, certains contrats de vente se forment avec un long processus de préparation (un processus complexe de négociation). Avec certains qui étaient déjà dans l'esprit des rédacteurs du code civil qui sont aujourd'hui désuées.

Premier type de processus de préparation pour les contrats de vente :

Les vente à l'agrée (le contrat de gré agrée, un consentement), on a un certain nombre qui doivent être signalés.

Tout d'abord la vente à la dégustation (**prévue à l'article 1587 du Ccn vins, huiles..**), on a des ventes qui sont soumises dans la conclusion est soumise à agrément de l'acheteur qui est discrétionnaire (selon son goût) et si son goût n'est pas positif il n'y a pas de vente.

Le vendeur ne peut pas discuter du goût de l'acheteur, cela ne sert à rien de remettre en cause le goût de l'acheteur car cela est personnel.

Ces ventes dont il est d'usage de goûter le produit aujourd'hui ce qu'il est d'usage de goûter à bien évolué, il peut y avoir des produits qui sont selon le code civil d'usage de goûter mais pas tout le temps ou dans n'importe quel type de vente.

Par contre, il y' a des hypothèses de vente où la vente est liée à l'agrée de vins par exemple mais pas en grande surface (en foire cela est possible)

Il faut se poser la question de savoir si on est vraiment en situation de vente est soumise à la dégustation de l'acheteur ?

Il faut que cela soit prévu soit entre les acheteurs, soit dans le contexte (des foires qui organisent des foires à dégustation)

La vente à l'essai (qui est prévu par l'article 1588 du code civil) « toujours faite présumée sous conditions suspensives), cet article nous dit juste son régime.

Un régime présumée n'est pas bon ou ne convient pas donc cet article n'est utile que pour nous signaler l'existence spécifique de vente faite à l'essai.

Une vente à l'essai est une vente dans lequel l'acheteur doit utiliser le bien avant de décider de l'acheter ou non. Mais cet essai nécessite l'utilisation du bien, il faut que cet essai permette à l'acheteur d'apprécier objectivement les qualités de l'objet de la chose.

C'est des périodes d'essai, c'est assez fréquent en matière d'animaux (matière de traie, que l'animal pousse ou tire), ou encore en matière d'outils informatiques (est ce que cela répond aux besoins de la personne). Cela fonctionne également avec les véhicules (voitures, motos, vélos..)

La période d'essai n'est pas une vente, le bien reste la propriété du vendeur mais il est utilisé par l'acheteur et il en reste propriétaire donc il en assume les risques de perte.

L'acheteur peut être maladroit et casser le bien qu'il est en train d'essayer, mais par définition il ne supporte pas les risques de cette destruction, en tout cas pas en tant qu'acheteur, il peut en revanche porter les risques de cette destruction en tant que faute (**article 1240 du code civil**).

Pendant la période d'essai il y a une relation contractuelle (par exemple location de skis).

Pendant cette période d'essai on organise l'utilisation du bien par l'essayeur, de sorte qu'il puisse essayer la chose. Il y a plusieurs techniques :

- la **location** (porte sur l'usage d'un bien)
- le **prêt des choses** (gratuit ou non), c'est plus fréquemment cette situation qu'on a plutôt qu'une vente sous conditions suspensives.

La plupart des cas il n'y a pas vente et on ne veut pas qu'il ait vente. Il va déjà promettre à son acheteur une **promesse unilatérale de vente** et c'est plutôt comme ça que la vente à l'essai s'organise plutôt que sous conditions suspensives qui ne protégé pas le vendeur.

Une promesse qui peut parfois être **synallagmatique** ou l'acheteur s'engage à acheter l'objet si l'essai correspond à des conditions précises.

Le contrat d'essai provisoire qui peut être une location ou un prêt, assorti d'une promesse (unilatérale ou synallagmatique)

Parfois en jurisprudence on ne se pose même pas cette question là et on règle cela uniquement sous la responsabilité civile, souvent avec les véhicules (surtout les véhicules chères) et les magistrats veulent partager les responsabilités, en disant que le vendeur comme l'acheteur sont tout les deux en faute et vont porter à 50/50 le préjudice qui est subi.

B – Les promesses

Qui va préparer à un contrat de vente.

1) Les promesses unilatérales

La promesse unilatérale est un contrat préparatoire dans laquelle une seule personne s'engage. Et selon qui s'engage ce sera une promesse unilatérale de vente ou une promesse unilatérale d'achat.

a) Le droit commun

Dans laquelle une personne promet soit de vendre soit d'acheter sous des conditions précises.

Le droit commun c'est **l'article 1124 du code civil** et le bénéficiaire de la promesse obtient un droit d'option (droit de dire oui ou non, le droit de lever l'option, le droit de ne pas lever l'option)

Cette droit d'option donne du temps à son bénéficiaire, celui qui a promis est déjà engagé mais celui qui bénéficie du droit d'option a encore le temps car il n'est pas encore engagée, il ne le sera que s'il lève l'option.

Il a un temps pour cela qu'il peut utiliser pour réfléchir (cela peut aussi être utilisé dans les contrats d'essai), à terme de ce temps de réflexion il peut lever ou non l'option).

Ce temps de réflexion est utilisé à pratique et cela peut être utilisé en dehors notamment dans le cas du **système des consignes**. Qui est fondée sur une promesse unilatérale d'achat et d'organiser un flux particulier.

Tout les systèmes de consignes sont organisés sous ce système de promesse unilatérale d'achat, notamment dans les **conventions de portage** (une personne veut acheter des actions de société mais il ne peut pas le dire tout de suite, il a pas encore l'argent, soit pour des raisons boursières il ne doit pas se faire passer pour un candidat à l'achat, il va s'adresser à une banque par exemple qui va être la en son nom, la banque n'est pas actionnaire, il porte juste les actions pour que la personne puisse s'organiser. Il y' a dans la convention de portage une promesse unilatérale d'achat à un prix fixé et les actions devront être achetés à ce prix défini à l'avance)

La promesse unilatérale de vente ou d'achat est une technique utilisé aussi bien dans les contrats de tout les jours que dans les grands contrats d'affaire '(on l'utilise aussi dans le dépôt-vente).

La plupart du temps elles sont gratuites, mais elles peuvent être payantes en tant que tel. Juste le fait de promettre c'est s'engager (à réserver), je ne peux pas le vendre à quelqu'un d'autre et je me prive d'une opportunité commerciale.

Ça peut se faire payer par une indemnité d'immobilisation en échange de l'immobilisation du bien)

Ça se paie avec soit **l'indemnité d'immobilisation** qui sera en déduction du prix de vente ou cela peut être à part et se rajouter au prix de vente. Attention : Cette indemnisation n'est pas un dédit ou une clause pénale, c'est juste le prix d'une immobilisation.

La promesse reste unilatérale si une seule partie s'est engagée en revanche le contrat devient synallagmatique.

Il existe des contrats synallagmatique de promesses unilatérales.

Lorsque indemnisation d'immobilisation est trop élevé le bénéficiaire n'as plus le choix de lever l'option et son consentement n'est plus (et cela n'est plus une promesse unilatérale)

Les conditions de validité :

Si la promesse va jusqu'au bout on va entraîner la vente automatiquement, donc il faut que dès l'origine toutes les conditions de la vente soient réunis au jour de la promesse (que la chose existe, que la chose soit déterminée ou déterminable, que le prix soit déterminable ou déterminée, il faut que la capacité de celui qui promet soit rempli)

La seule chose dont on a pas besoin est la capacité du bénéficiaire, car il ne supporte aucune obligation particulière (sauf si y'a un prix), c'est une capacité minimale qui lui est demandée, mais le jour ou il devient acheteur on appréciera sa capacité et faudra qu'il ait la capacité suffisante pour conclure le contrat.

Pas de conditions de formes pour les promesses unilatérale de vente, sauf pour les biens les plus fréquents (c'est-à-dire les immeubles, il y' a alors des formes imposés notamment avec **l'article 1789-2 du code civil**, ou dans le code de la construction et de l'habitat, la forme authentique est

requis, c'est-à-dire devant un notaire) mais en dehors de ces cas précis aucune forme n'est demandée.

Le bénéficiaire de la promesse peut-il se faire substituer quelqu'un d'autre ? Est-ce que le bénéficiaire peut ou non céder son option ?

Oui, si les parties le prévoient, le caractère de la promesse est quand même institut personæ. Qui n'est pas d'ordre public donc les parties peuvent très bien l'écarter.

Est-ce une cession de contrat ? Ou une cession de dette ?

(Cela fait partie des grandes questions du régime général de ..)

Cette faculté de substitution est fréquemment utilisée notamment dans le domaine immobilier avec les marchands de biens, qui se positionnent sur les biens immobiliers sans les acheter (ils obtiennent des promesses de vente qu'ils vont vendre à des clients et font profiter au client de leur droit d'option devant le notaire, de sorte qu'il n'y ait qu'une seule vente entre le vendeur et le client final)

Est-ce qu'on peut révoquer ou rétracter les promesses unilatérales de vente ?

Tant que l'option n'est pas levée mais qu'elle peut encore l'être le promettant ne peut pas conclure le contrat de vente avec un tiers (il est tenu de contracter car il s'est déjà engagé).

S'il se rétracte quand même on va faire en sorte que sa rétraction n'ait pas d'effet.

Pendant longtemps la cour de cassation considérait que ce n'était qu'une obligation de faire pour le promettant et cela a été modifiée avec la réforme de 2016 désormais **l'article 1124 du code civil** donne un véritable pouvoir au bénéficiaire de la promesse car la rétractation qui est faite durant la période de la levée d'option, la révocation n'empêche pas la formation du contrat promis.

Le bénéficiaire peut décider de lever l'option et obtenir l'exécution du contrat de vente et sa formation.

Si le vendeur a déjà conclu le contrat avec un tiers, cela dépend de la connaissance de la promesse :

- si **le tiers connaissait l'existence de la promesse**, il y a toutes les raisons pour l'obliger à rendre le bien et le vendeur indemniser le tiers
- **le tiers ne connaissait pas l'existence de la promesse**, l'exécution forcée en nature est exclue et le bénéficiaire de la promesse ne pourra prétendre qu'à des dommages et intérêts dus au promettant.

b) Régimes spéciaux

Il existe des régimes spéciaux en dehors du droit commun que l'on trouve :

- **la vente à la dégustation** (le dégustateur a une option)
- **la vente à la consommation** (dans le code de la consommation, tout ce qui concerne les promesses unilatérales en matière immobilières, la relation unilatérale de vente et d'achat et le prêt, c'est-à-dire le financement de l'achat par l'acheteur, qu'il ne soit plus tenu par cette promesse d'achat s'il n'a pas obtenu les frais pour réaliser cet achat.)
- **le code d'immeuble et d'habitation** (les promesses unilatérales de vente ou d'achat, dans la vente d'immeubles à construire, le constructeur a de l'argent pour construire qu'une partie de l'immeuble et il n'aura de l'argent que s'il vend cette partie de l'immeuble, la vente de plan)

Il essayent d'obtenir des promesses d'achat, pour demander au banquier de leur faire un prêt d'argent (ce qui reste risqué tout de même pour l'acheteur)

2) Les promesses synallagmatiques

a) Définition et qualification

On a avec ces deux actes séparés, une promesse synallagmatique ou deux promesses unilatérales qui restent différentes. **L'article 1589 du code civil** qui nous dit que promesse synallagmatique de vente vaut vente.

Imaginons que ce soit deux promesses unilatérales séparées. Lorsqu'on a un droit de préemption (une personne est prioritaire pour la vente), sauf que ce droit ne s'applique que s'il n'y a vente.

Mais s'il a promesse unilatérale de vente et d'achat croisé avec il n'y a pas vente.

La jurisprudence a des positions qui sont assez factuelles (soient elles considèrent que les parties n'ont pas voulu retarder la vente, donc promesse synallagmatique ou sinon elles admettent que les parties admettent l'hypothèse d'une non vente avec une promesse caduque). La jurisprudence utilise l'expression « d'engagement synallagmatique » sans qu'il ait promesse synallagmatique.

Très utilisés en matière d' »intégration agricole, par exemple les éleveurs de poule, font juste de l'élevage (c'est-à-dire qu'ils achètent des poussins et ensuite ils vendent des poules).

En matière de convention de portage on peut avoir des promesses croisées (l'un s'engage à vendre et l'autre s'engage à acheter)

b) La question de l'article 1589 du Code civil

Dont l'alinéa premier « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties comme la volonté sur la chose et sur le prix »

La question vient d'un verbe qui a plusieurs sens « **valoir** », il n'a pas qu'un seul sens.

On peut le comprendre comme signifiant :

- la promesse synallagmatique de vente est équivalente dans ses effets
- cela ne veut pas dire que c'est une vente, cela veut dire que ça peut effectivement avoir les mêmes conséquences mais ce n'est pas une vente

La jurisprudence n'applique pas de manière automatique **l'article 1589 du code civil**, ce n'est pas une obligation pour la jurisprudence et pour le juriste d'appliquer à la règle cet article.

Cet article oblige le juge à analyser la volonté des parties, à aller au delà de la simple appellation du contrat, en se questionnant sur le fait de savoir; **Qu'est ce que les parties ont réellement voulu ?** (une promesse synallagmatique autonome ? Promesse de réitération ? Une vente)

La vente

Certaines promesses unilatérales de vente sont des véritables ventes qui peuvent prendre trois formes différentes :

- **une vente ferme** (elles sont déjà engagés réciproquement, on applique **l'article 1589 du CC**)
- **une vente sous conditions suspensives** (par exemple, pour gérer l'obtention d'un prêt ou d'un permis de construire
- **une vente avec un terme** (laisser un certain temps mais en réalité les deux parties sont

engagés et les magistrats requalifient les conditions), dans ce cas là **l'article 1589 du code civil** n'as pas besoin d'être utilisé. Il n'y a besoin d'aucun accord supplémentaire et si par hasard les parties ne vont pas devant le notaire)

La réitération

Des promesses peuvent révéler les intentions des parties, de conditionner ce contrat de vente à un événement futur entièrement soumis à leur consentement.

Elles veulent se réserver une sorte de Je m'engage à exprimer mon accord mais je ne peux pas faire plus, à ce moment la le contrat n'est pas une vente car il y' a une réserve dans le contrat.

L'engagement réciproque des parties pour réaliser l'acte lui même en donnant à ce moment là leur consentement définitif et la naissance du contrat est retardée volontairement par les parties

L'article 1589 du code civil, est utile dans ce la selon son exacte utilisation. Cet article sert à savoir comment s'exécute la promesse.

Le juge à le pouvoir de prononcer la vente, son jugement vaut vente définitif et dans ce cas ci l'article est utile.

Une vente avec une faculté d'édit payante. De sortir du contrat en supportant un prix (un coût, une indemnité), on appelle cela des arts en principe.

Une promesse synallagmatique autonome

Elle est utile lorsque les parties veulent que leur accord porte non seulement sur les éléments essentiels du contrat (le prix, le transport..) mais aussi sur les éléments accessoires du contrat (la date de livraison, charge des frais de livraisons, des taxes associés à la vente).

Ces éléments qui d'après le code civil ne sont que accessoires, les parties les ont perçus comme essentiels dans la promesse. Elles vont réserver leur accord définit à une mise au point sur des éléments autres.

Cette promesse synallagmatique de vente elle exclut toute exécution forcée, et dans cette hypothèse il n'est pas question d'appliquer **l'article 1589 du code civil**, car la promesse synallagmatique de vente ne vaut pas vente et sert uniquement à éclaircir des points essentiels mais sur lequel ils ne se sont pas fixés.

L'article 1589 du code civil n'est que supplétif, cela implique tout de même que le juge décide selon la volonté des parties de classer la promesse (vente ? Réitération ? Promesse synallagmatique autonome ?)

C – Le pacte de préférence

Le pacte de préférence qui est défini à **l'article 1123 du code civil**.

Cela marche pour tout les contrats dont les contrats de vente, c'est un avant contrat qui permet de préparer. C'est un droit de préemption conventionnel.

Dans le pacte de préférence, le promettant ne donne pas son consentement au contrat futur. Il

s'engage à offrir un achat si il lui vient de vendre ce bien, mais il a aucune obligation à le vendre.

C'est un engagement contractuel qui a un régime juridique et des éléments doivent attirer l'attention :

- **le premier délai : la durée d'efficacité de la préférence** (le promettant peut s'engager avec une durée déterminée ou indéterminée, si le pacte de préférence ne précise pas de durée le promettant est tenu de respecter le pacte tant qu'il n'as pas tenu de vendre le bien)
- **le second délai ; combien de temps le bénéficiaire peut encore en profiter ?** (cela peut être dit dans le pacte de préférence à l'avance, il peut y avoir un délai indéterminée c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu de délai, sois il y' un délai implicite et c'est le juge qui va le trouver, sois le délai de prescription qui est la solution technique.)

Quand est ce qu'on utilise les pactes de préférences ?

On l'utilise beaucoup en pratique dans des situations immobilières avec des ventes partielles. Le fait d'acheter le premier, on a le droit de priorité.

On peut avoir ce type de préférence en cas de revente

On les retrouve également dans les contrats de société, c'est-à-dire des pactes dites de préemption. Dont les bénéficiaires sont les associés en place et dont les promettant sont tout les associés.

En matière de distribution commerciale, avec des clauses d'offres concurrentes ou de premier refus.

La sanction du pacte de préférence

Prévue à **l'article 1123 du code civil**, remarquons que dans cet article il y' a une action interrogatoire, c'est-à-dire que l'existence de ce pacte de préférence est un épée Damoclès pour celui qui l'as donné et pour quelqu'un qui voudrait bien acheter le bien.

§ 2 – La protection des consentements

A – Le consentement des contractants

1) Le consentement protégé

Le consentement des contractants. Il faut envisager alors deux points :

- **ce qui permet de le protéger** (un consentement qui est protégé dans le cadre de la formation du contrat de vente)
- **un consentement forcé**

Le but du CC c'est se s'assurer que les consentements soient données de manière libre et éclairé. S'agissant du contrat de vente, il faut que le consentement de l'acheteur soit libre et éclairé et il doit tout de même faire preuve de curiosité.

Qu'il ne soit pas totalement passif, il y' a plusieurs raisons qui expliquent la curiosité qu'on attend de la part de l'acheteur : ce n'est pas un incapable et le vice du consentement sont déjà là pour le protéger et ce la protège notamment de la réticence dolosive du vendeur.

Faut il aller au delà de cette protection de droit commun qui est offerte par le code civil ?

Le législateur et la jurisprudence ont considéré que dans certains cas il faut aller au delà de la protection du droit commun du code civil.

La jurisprudence a découvert puis étendu une obligation général d'informations, une obligation pré-contractuelle. Depuis 2016, elle a été consacrée dans le code civil **article 1112-1 du code civil**.

Ce qu'on doit vraiment signaler c'est l'information spécifique à certaines ventes qui se sont multipliées (en matière immobilière, **article 1104** qui imposait au vendeur et qui ont ajouté d'autres informations spécifiques d'autres textes qui imposent une série d'informations faites par des experts.. Il y' a des textes qui sont la pour informer l'acheteur sur l'état antérieure du bâtiment, une activité industrielle, polluante, est ce qu'il y' a la présence de mines ?..)

On a des dispositions spécifiques pour des immeubles qui sont des lots de co propriété (règlements de propriété, descriptif des parties communes..). La **loi carrez** impose aux acheteur de donner à l'acheteur le nombre de mètres carrés.

Il y' a de plus en plus de textes qui s'appliquent à des ventes particulières pour renforcer et préciser les informations préalables qui pèsent au vendeur et sur la protection de consentement de l'acheteur.

On a ce type de précision pour les ventes au consommateurs (**articles L111-1 du code de la consommation**), on va avoir des dispositions s'agissant de la vente au consommateur (des informations préalables renforcées qui participent à la protection du consommateur) **Article 1638 du code civil** par exemple.

1) Le consentement forcé

Il existe des limites à la liberté contractuelle mais il y' a des exceptions à cela : ces limites sont souvent édictées par le législateur avec l'ordre public de direction ou de protection. Un ordre économique et spécial qui est la pour diriger l'économie, ou protéger des personnes, des parties.

On a des hypothèses de ventes forcées, en revanche on a des hypothèse d'obligation de vendre. Par exemple l'expropriation pour cause d'utilité public (**l'article 545 du code civil**), il y' a des garanties (dans le respect du droit constitutionnel qui protège la propriété) ces garanties sont surveillés par le juge judiciaire.

Il existe des obligations et des cas d'obligations de vente quand certaines conditions sont respectées.

Dans le code civil, **l'article 661 du code civil** donne à tout propriétaire la faculté d'imposer à son voisin de vendre la moitié du mur mitoyen (le mur à la frontière entre deux propriétés). Il a donc vocation à appartenir aux deux fonds propriétaires. Parfois on a un mur mitoyen qui appartient qu'à un seul des deux propriétaires et dans ce cas là l'autre à la possibilité de devenir le co propriétaire de ce mur (la moitié du mur).

On doit aussi mettre en avant la question des voies d'exécutions, c'est-à-dire par exemple la vente forcée des biens du débiteur (une vente aux enchères généralement), on saisit les biens du débiteur (défaillant) sans son accord pour les vendre.

Puis, il y' a une autre hypothèse en matière de divorce, cette vente un peu forcée que l'on décide pour la paiement de la prestation compensatoire et pour éviter qu'elle se fasse de manière échelonnée on incite désormais à une prestation compensatoire payée en 1 seule fois et on peut

décider de la vente forcée de l'usufruit ou de la pleine propriété d'un des biens des époux.

Il faut se poser la question du régime de ces ventes forcées ? Quel est le régime applicable à toutes ces ventes ?

Notamment le cas où le vendeur n'est pas d'abord, est-ce qu'il doit être comme n'importe quel vendeur garant des vices cachés de la chose ? Responsable des éventuels problèmes, défauts de la chose qu'on lui a forcée à vendre ?

Autre hypothèse où le consentement est imposée, celui ou le co contractant est imposée, on va lui désigner l'acheteur :

- **le droit de retrait**, par exemple le droit de retrait litigieux (**l'article 1699 du code civil**)
l'hypothèse ou un débiteur cédé mais à un prix inférieur à la dette.

Ou encore, le droit de retrait qui profite à la réunion des musées nationaux qui dispose d'un droit qu'elle peut activer dans le cas de ventes aux enchères publiques d'objets d'arts. Une fois que l'adjudicataire est désigné la réunion des musées nationaux peut prendre sa place au prix dont on est arrivé au terme des enchères (**article L181-1 code des patrimoines**)

On a aussi un droit de retrait qui appartient à l'administration fiscale, un impôt qui est calculé sur la valeur du bien vendu. On va dire que la vente a été faite à un prix inférieur à son prix réel et on va payer une soulte (illégalement), l'administration fiscale a un droit de retrait (**prévu dans l'article L18 du livre des protection fiscales LPF**)

- **le droit de préemption**, cela se passe avant la vente c'est-à-dire au moment du projet de la vente. C'est ce droit donné à un tiers d'être prioritaire en cas de projet de vente. Dans ce cas la le vendeur qui a le projet de vente n'a pas le choix, il a un acheteur prioritaire et si cet acheteur se déclare il doit le vendre à lui obligatoirement.

Ces droits de préemptions peuvent être légaux (la loi qui en décide et qui les attribue) ou conventionnels (pacte de préférence).

Par exemple le droit de propriété, lorsqu'on est locataire d'un bien d'habitation, le propriétaire doit en propriété le proposer à son locataire s'il veut vendre sa propriété (preneurs à bail)

Il y a des droits de préemptions qui profitent à l'état ou aux collectivités territoriales (par exemple les communes ont un droit de préemption sur les commerces, la SAFER qui vise les biens ruraux, c'est-à-dire les champs et les terres agricoles et pour les attribuer en suivant une politique publique agricole, des départements qui ont des droits de préemption sur des terres qui sont des espaces protégés et naturelles, par exemple en Camargue)

Ces droits de préemptions impliquent pour le vendeur et l'acheteur de purger le droit de préemption, il y a souvent un délai, il faut alors exprimer le projet de vente, purger le projet de vente, attendre qu'il se prononce et faire la vente et c'est alors lui qui deviendra acquéreur du bien.

Il peut y avoir des droits de préemptions conventionnels (en matière de droit de société, dans les groupes de sociétés avec la technique du Squish Out, qui profitent aux associés majoritaires pour racheter les titres des minoritaires)

La règle prévoit la sanction qui y correspond ; des nullités, des inopposabilités, des substitutions de force, ou encore une réparation (un dédommagement

B – Les formes du contrat

En principe il n'y a pas de forme à suivre pour la conclusion du contrat de vente, en matière de

certaines ventes, formalités sont soit imposées soit indispensables en pratique. Notamment en matière de vente, ou l'écrit est une formalité indispensable parce qu'elle permet de régler toutes les questions de preuves et donc elle donne aux parties une sécurité juridique irremplaçable.

Donc il faut bien discuter de la forme, il existe des formalités spécifiques imposés et puis de toute façon il y a la question de l'utilité pratique et l'écrit est irremplaçable à cet égard.

1) Formes des ventes immobilières

En matière immobilière il y a surtout une formalité qui est la réalisation d'**un acte authentique**. Cette formalité est liée à la question de la publicité foncière (l'enjeu n'est pas la validité de la vente,) l'acte sera valable seulement il sera inopposable au tiers.

Il faut procéder à une formalité de publicité foncière qui implique un écrit et un acte authentique. Pour certains biens immobiliers il y a des formalités obligatoires notamment :

- **les mentions obligatoires** (la vente de l'eau en propriété et cela doit se trouver dans l'acte lui même au titre de mention obligatoire). Le diagnostic est dans l'acte de vente, aujourd'hui les documents relatifs à l'organisation de propriété sont dans l'acte, la situation financière de co propriété également.

1) Formes des ventes mobilières

Est ce que dans les ventes mobilières il y a des mobilités ?

Il y en a moins mais il y en a tout de même, notamment dans des textes spéciales qui les imposent :

- **les ventes électroniques** obéissent à des règles de formalisme particulière (déterminée dans le code de la formation et dans le code civil, **article 1127-2 du code civil**)
- **les ventes au consommateurs** (dans le code de la consommation)
- **les ventes à distance** (droit de rétractation de 14jours, prévue dans le code de la consommation)
- **imposés à l'écrit par le législateur** ventes de bateaux de navires, d'avions, la cessions de revêt, de marque.

Le législateur peut imposer dans certains types de biens meubles des mentions obligatoires dans l'acte qui est lui même exigée par écrit, par exemple les cessions de fond de commerce (les chiffres d'affaires sur les 3 dernières années qui est demandée) ce qui a été allégée par le législateur plus tard)

Pour la vente de bien mobilier il peut y avoir des formalités, le consensus existe toujours en qualité qu'en formalité.

Section 3 - Objet de l'accord de volontés

L'article 1583 du code civil, ce qui est essentiel dans le contrat c'est ce qui est .. par la chose et le prix.

§ 1 – La chose

La chose doit exister et s'approprier.

A – L'existence de la chose

1) L'existence matérielle de la chose

La chose doit matériellement exister et faut qu'elle soit juridiquement déterminable. Ce qui impose les cas où cette existence est remis en cause, mais ça peut être plus délicat dans hypothèses où la chose a par exemple péri (elle a été détruite), c'est l'hypothèse la vente de la chose périée.

Traité dans le code civil dans **l'article 1804 alinéa 1 du code civil**. Si vente est périée totalement la vente est nulle et si la chose est partiellement détruite l'acheteur peut arrêter la vente ou continuer la vente mais en la refaisant (hypothèse de réfraction du contrat)

La vente de chose future, c'est-à-dire la chose n'existe pas encore mais elle a vocation à exister. Peut-on passer un contrat sur une chose future ?

Prévue dans le code civil avec **l'article 1163 du code civil**, il suffit juste que la chose soit déterminable (par exemple, la vente de chose à fabriquer, la vente d'une récolte à venir, la vente du coup de filet, en matière audiovisuel...)

Cette vente de chose future peut être soit :

- **connotative**
- **une vente aléatoire** (le coup de filet), on détermine le prix de la chose mais on n'en connaît pas le volume, la quantité

Le législateur est intervenu pour certaines formes de ventes de choses futures, par exemple en matière de droits d'auteurs le législateur interdit la cession globale de ses œuvres futures (il ne peut lui en céder que 5), en matière immobilière pour la vente d'immeuble à construire (qu'il a réglementée)

1) La détermination juridique de la chose

La chose doit exister matériellement et juridiquement, c'est une condition qui découle de l'article **1163 du code civil et repris dans l'article 1583 du code civil**.

Il n'y a aucune difficulté lorsque la chose est encore certaine (on l'a dans les mains, on peut le toucher, il est désigné et individualisé), mais lorsque la chose est une chose de genre (pas individualisé, on voit le concept, l'image, un modèle mais il en existe des centaines de milliers d'exemplaires, par exemple des chaises Ikea) la difficulté augmente.

Ce qui implique une individualisation et l'on considère que tant qu'elles sont à individualiser, elles sont déterminables mais pas déterminées.

On a le même problème avec la chose de genre qui se fait au poids, au volume.. il faut l'individualiser pour qu'il ait effectivement vente.

Il n'y aura que véritable vente que lorsque la chose de genre aura été individualisée.

On a le même type de difficulté avec la vente à distance, l'acheteur ne peut pas toucher la chose même si elle est certaine, et la l'individuation ne se fera que lorsque la marchandise sera remis au transporter et lorsque le vendeur s'est séparé du bien.

L'individualisation de la chose va entraîner le transfert de propriété et mécaniquement le transfert des risques et cela a des conséquences assez fortes.

B – L'appropriation de la chose

Pour que la chose puisse faire l'objet de vente il faut que deux conditions soient réunies :

- l'objet d'un droit de propriété
- appartenir au vendeur

1) Les choses hors commerce

Ça nous impose de parler nécessairement des choses hors commerce et qui ne peuvent pas faire l'objet de droit de propriété. L'article 1580 du Code civil, toutes les autres choses peuvent.

Il n'y a que les objets hors commerce qui ne peuvent pas faire l'objet de vente. Certains objets de commerces illicites ne peuvent pas faire partie d'un objet de vente car elles vont rendre le contrat illicite.

Cette conception est assez mouvante/changeante selon le législateur.

Mais il y' a des choses catégorisées de manière sure :

- **le corps humain** (les sépultures, le droit de la famille..)
- **les choses relevant du domaine public** (tant qu'elles sont dans le domaine public elles sont hors du commerce mais si elles en sortent alors elles seront plus hors commerce)
- **l'investiture politique** (le droit de se présenter à une élection, non ce n'est pas un droit dans le commerce)
- **les clientèles civiles** (des professionnels libéraux), on ne pouvait pas les vendre aujourd'hui on peut les vendre.

Toute cette catégorie est mouvante et cela peut changer.

Après la question se pose de savoir si les parties elles même peuvent ou pas rendre eune chose inaliénable ?

La question de inaliénabilité conventionnel : la réponse est oui, donnée par **l'article 900-1 du code civil** et possible dans le cas de libéralité. C'est possible mais il faut que ce soit temporaire.

Est ce que cela est possible par contrat de vente ? La doctrine et la jurisprudence considèrent que non on peut pas conventionnellement décider de inaliénabilité d'un bien.

1) La chose d'autrui

Il faut qu'elle soit appropriée par le vendeur. Les hypothèses ou le vendeur vend une chose qui n'est pas à lui. L'hypothèse de la vente de la chose d'autrui prévue à **l'article 1599 du code civil**.

« la vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur à ignoré que la chose fut à autrui »

L'adage « d'inconnu nul ne peut transférer plus de bien qu'il n'as déjà »

C'est aussi une conséquence assez logique du principe d'immédiat du principe de transfert propriété en matière de contrat de vente. Il y a vente dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix. Il y a vente en matière de transfert de propriété et il y a un côté immédiat et automatique.

Cette règle c'est aussi la conséquence de l'immédiate du transfert de propriété prévue par le code civil. Mais **l'article 1583 du code civil** n'est pas d'ordre public. On peut retarder le transfert de propriété.

C'est alors supplétif, cela change tout car si les parties repoussent le transfert de propriété on peut la regarder différemment. Au moment de l'accord de propriété la chose peut ne pas être la propriété du vendeur, il suffit qu'elle le devienne après. Donc on ne doit pas regarder cet article comme une règle indépassable.

Si par hasard on repousse le transfert de propriété et que la chose n'est toujours pas la propriété du vendeur, la vente sera nulle. Par contre si le vendeur a enfin obtenu la propriété de ce bien alors il pourra le vendre.

Ça pose aussi la question des ventes successives. Il arrive qu'un vendeur qui doit être propriétaire de la chose le vende à plusieurs acheteurs et on va être confronté à un conflit.

Qui va primer ? Qui va se proclamer comme étant le seul et l'unique propriétaire de la chose vendue ?

Normalement la règle de transfert de propriété implique que ce soit le premier qui soit le propriétaire, En matière mobilière c'est **l'article 2276 du code civil** « la possession de bien meuble vaut titre » le premier qui aura la chose entre les mains sera propriétaire (même si c'est le 2nd acheteur). Faut que cette possession de bien meuble soit **de bonne foi**, sinon il ne sera pas considéré comme propriétaire de la chose.

Pour les biens immeubles c'est la publicité foncière qui règle ce problème, celui qui gagne le produit c'est la premier publié, en fonction de celui qui a le premier publié son titre, son acte.

§ 2 – Le prix

Dans une vente il faut qu'il ait un prix qui est par définition nécessairement une somme d'argent. S'il n'y a pas de prix ce n'est pas une vente. A ce prix il faudra ajouter les accessoires du prix.

L'article 1593 du code civil parle des frais et accessoires avec une petite précision la TVA (un impôt particulier qui reste à la charge du vendeur) reste nécessairement à la charge du vendeur et pas autrement parce que ce n'est pas un accessoire du prix.

Ce prix doit être déterminée ou déterminable , l'article 1591 du code civil qui impose cette détermination. Par exemple, on a dans le code civil français laissée la possibilité pour les parties de confier à un tiers le soin de fixer le prix (**article 1591 du code civil**)

Le prix peut aussi être déterminée par des éléments prévue à l'avance par les parties, par exemple le profit future que peut confier l'acheteur à la chose

Les parties ont la possibilité de dire que le prix sera celui du vendeur au jour de la livraison, ce qui pose problème c'est-à-dire que si le contrat de vente est conclu, la chose est déterminée et que le prix est seulement déterminable et que cela est laissée à la décision du vendeur l'acheteur risque de se faire avoir.

Cela est quand même possible, le code a posé la limite de l'abus.

Le prix dans le contrat de vente doit être **réelle et sérieux** (pas un prix simulée, fictif, dérisoire). Là une question se pose s'agissant des ventes à l'euro symbolique. Cela l'est si la chose est sans valeur, mais cela pose problème lorsque la chose a une grande valeur.

Il y' a des cas où derrière l'euro symbolique il y' a d'autres engagements (par exemple payer une entreprise qui a des dettes à l'euro symbolique, mais c'est peut-être plus une vente). Il est alors important de se poser la question de la qualification.

L'existence du principe des libertés des prix, en France c'est une liberté constitutionnelle. Ce principe souffre de quelques exceptions (par exemple, la baguette de pain, et le prix du livre)

La question de la justice du prix, Est-ce que le prix est effectivement l'équivalent du bien ? Une question qui renvoie à la législation pour lésion, il y' a dans le code civil des articles qui traitent de cela.

Section 4 – Les effets de la vente

Les effets de la vente sont de deux catégories :

- les effets réels (au sens de chose, res)
- les effets

§ 1 – Les effets réels

Le premier effet réel est le transfert de propriété qui est organisée par le code civil qui dit de oui qu'il est automatique dès lors que les parties se sont mis d'accord.

Ce transfert n'est pas prévu de manière impérative.

A - Le transfert de propriété

1) Prévu par le Code civil

L'article 1583 du code civil qui dit que le transfert de propriété est fait « **solo consensus** » c'est un effet réel et automatique ce n'est pas une obligation qui pèse sur le vendeur.

C'est une conception évoluée qui dissocie le droit et la chose.

Ce transfert est gênant dans le sens où c'est un droit opposable à tout le monde (erga omnes)

C'est-à-dire qu'il n'est plus propriétaire de la chose mais qu'il a encore la chose entre les mains (le système de publicité dans le cas de biens immobiliers, bateaux, navires, avions..

Ce qui nécessite une individualisation de la chose et une appropriation de la chose, mais ce transfert de propriété solo consensus n'est pas obligatoire (les parties peuvent dire autre chose, aménager le transfert de propriété)

2) Aménagé par les parties

Les parties peuvent jouer sur le moment du transfert de propriété, par exemple la condition

(conditions suspensives ajouté) ou le terme (on attend une date qui peut être certain ou incertain).

On peut le faire avec une clause spécifique, qui est en fait une condition. La clause de réserve de propriété est intéressante lorsqu'il y a une livraison par exemple. Cette réserve de clause de propriété joue un rôle de garantie de paiement.

Cette clause doit être obligatoirement écrite et elles sont spécifiées dans le code civil (**article 2367 et suivants du code civil**)

B – Le transfert des risques

Le principe c'est que le risque pèse sur le propriétaire (res peri domino), c'est lui qui les assume. C'est le principe du droit français et qui est exprimée à **l'article 1196 du code civil**.

Cela veut dire que avant la vente lorsqu'il n'y a pas eu transfert de propriété celui assume la chose est le vendeur, quand il y a vente au moment de la vente les risques passent sous la tête de l'acheteur.

On peut retarder le transfert de propriété donc on peut retarder le transfert de risque avec.

Si la vente est annulée, l'annulation a un effet rétroactif, cela veut dire que le vendeur est sensé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire et l'acheteur n'as jamais été propriétaire. Entre temps la chose peut avoir péri (par exemple une vente de vaches)

Ce principe supporte quelques exceptions qui sont liés à un transfert de propriété retardée, à raison de conditions suspensives, ou encore d'une individualisation qui arrive plus tard. Il y a aussi la question du retard,

Par exemple, si le vendeur tarde à livrer la chose, cela va entraîner comme conséquences que les risques vont revenir sur la tête du vendeur.

Les règles de transfert de propriété sont supplétives et les règles de transfert de risques sont aussi supplétives et les parties peuvent dissocier les deux. Si elles le font pas on appliquera le principe.

§ 2 – Les effets personnels

Ce que les personnes concernés vont subir.

A – Les obligations du vendeur

L'article 1602 du code civil, une obligation d'explication. Expliquer ce à quoi il s'oblige. C'est le mieux placé pour connaître la chose et il est informée sur la chose et la vente de la chose.

L'article 1603 du code civil nous montre que le vendeur à deux obligations principales :

- **il doit délivrer la chose**
- **il doit garantir la chose**

La jurisprudence oblige par exemple une obligation de conseil, une obligation de sécurité, d'autres obligations qui vont dépendre de différents facteurs. Il y a une multiplication des obligations qui pèsent le vendeur.

Cela protège l'acheteur, cela responsabilise le vendeur mais attention cela entraîne une hausse des coûts des assurances, et mécaniquement cela entraîné une hausse des prix.

1) L'obligation de délivrance

Cette obligation est précisée par **l'article 1604 du code civil**, qui nous dit « la délivrance et le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». La délivrance ne transfère pas en principe le propriété du bien et il ne transfère pas la possession (qui nécessite une action de la part de l'acheteur)

C'est en réalité une mise en disposition de l'acheteur d'une chose conforme en stipulation contractuelle.

C'est une obligation qui lui impose de mettre à disposition de l'acheteur une chose conforme aux stipulations contractuelles. Cette obligation lui impose de traiter quelques questions lorsqu'on parle de mise à disposition de chose.

Il faut faire une différence entre la conformité de la chose et la chose qui est atteinte d'un vice caché.

Quand il y a une chose non conforme c'est qu'il y a une différence entre les stipulations contractuelles qui décrivent la chose et la chose elle-même qui est remise à l'acheteur.

C'est **un critère matériel** mais subjectif, on parle alors de '**alioud**' (alter) c'est-à-dire la chose étrangère. Pour marquer la différence entre ce qui était prévu et qui a été mis à disposition concrètement, c'est la non conformité.

Le vice caché n'est pas une comparaison, c'est un défaut. C'est-à-dire que la chose est là et elle a l'air de correspondre à ce qui a été prévu simplement elle a été affectée d'un défaut qui le rend impropre à son usage normal. C'est une chose amoindrie '**pejus**' (le moins bien) c'est **un critère ici fonctionnel** et qui est plus objectif.

Par exemple, quand on demande un ordinateur avec une certaine puissance et qu'on nous livre un autre ordinateur avec une autre puissance, ça répond pas aux stipulations, ou encore qu'on nous livre un écran qui n'était pas prévu et c'est donc un problème de stipulations.

En revanche vous achetez des tuiles et on vous livre des tuiles dont l'usage normal est de nous protéger des intempéries et ces tuiles sont gélives (sensibles au gel), simplement elles ne répondent pas à l'usage normal. C'est alors un vice caché.

C'est un vice caché lorsque la chose ne permet pas de remplir la fonction normale.

C'est assez embêtant parce qu'il y a des régimes juridiques radicalement différents. Ne serait-ce qu'en terme de délai de prescription. La jurisprudence a posé le principe du non cumul d'actions (on ne peut pas agir à la fois en tant que vice caché et de la non conformité), on doit choisir son terrain. Il y a une véritable différence de régime entre les deux, en revanche c'est une source de problème tellement importante qu'en matière de vente de consommation on a écarté la différence entre les deux, et le projet de réforme de la commission propose aussi un alignement des régimes (c'est-à-dire d'arrêter de faire la différence entre deux). Mais pour l'instant cette distinction existe.

Les accessoires

L'article 1615 du CC impose de délivrer la chose mais aussi ses accessoires, ' la délivrance de la chose comprends ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel', il faut mettre à

disposition la chose qui a été prévu, plus d'éventuels accessoires, il y en a de deux types :

- il y' a d'abord **les accessoires qui sont produit par la chose** (les fruits), par exemple les loyers sont les fruits de la chose, si vous vendez une créance qui porte intérêt, les intérêts sont les fruits de la chose parce qu'ils sont produit parla chose
- **les accessoires affectés au service de la chose**, ils ne sont pas produit par la chose mais il lui sert. Par exemple vous achetez une voiture, il faut fournir une roue de secours, une cricque pour réparer cette roue ou encore une carte grise

Il y a ces accessoires qu'il va falloir comprendre dans la délivrance de la chose. L'obligation de délivrance les vise tous (tout ceux qui sont nécessaires). Ça peut être aussi pour un droit immobilier une hypothéqué, une certitude..

Ça peut être aussi un contrat (en principe non, mais il y a des exceptions et le contrat est un accessoire de la chose) par exemple, en matière d'immeuble, quand vous cédez une entreprise.

,Il faut bien comprendre dans cette idée de la délivrance qu'il ya la chose, plus les accessoires.

Le lieu

La délivrance n'est pas une livraison **l'article 1609 du CC** dit qu'en principe ' c'est à l'acheteur de venir retirer la chose, c'est-à-dire de venir au domicile du vendeur.' L'obligation de délivrance est une obligation de ne pas faire (de ne pas empêcher l'acheteur de venir retirer la chose).

Il faut faire en sorte que le retraitement de la chose ne se fasse pas systématiquement chez le vendeur (par exemple l'immeuble, le retraitement se fait par le vendeur qui donne les clés à l'acheteur, pour les aliments la délivrance se fait par marquage, on marque les animaux et les arbres.)

Le délai

Quand est ce que se passe le délivrance ?

Ça peut se faire immédiatement, ou après il y a vente dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix. Dans les relations avec les consommateurs, le professionnel à l'obligation d'indiquer une date de délai face au consommateur. (**article L111-1 du code de la consommation**)

Que se passe t-il si le vendeur ne s'exécute pas (**article 1610 et 1611 du code civil**), il ressort de ces articles que l'acheteur à une option, si le vendeur est en retard et n'exécute pas sa délivrance l'acheteur peut soit demander l'exécution forcée soit la résolution du contrat

Il existe des nuances selon la sous catégorie de vente (en matière de **vente au consommateur article L217-9** qui est un régime assez spécial

1) Les garanties

Garantie qui est mot juridique précis, c'est pas une obligation. C'est une garantie, dans le mot de garantie à la différence de l'obligation il y' a une automaticité. Dans l'obligation il y a toujours cette idée de faute.

C'est-à-dire que l'obligation se résout avec des dommages et intérêts et encore faut il qu'il ait eu une faute, ou qu'il ait eu préjudice lié à cette faute. C'est le critère de la mise en sanction.

En matière de garantie la faute n'est pas en scène, la garantie elle est automatique et en la matière le

vendeur à deux garanties :

- **contre l'éviction**
- **contre les vices cachés**

Garantie contre l'éviction

Les **articles 1626 et suivants du code civil**. La garantie contre l'éviction elle impose d'abord au vendeur une garantie de son fait personnel, il ne doit pas évincer l'acheteur de son propre fait. La garantie contre l'éviction se subdivise en différents types de garantie :

- **la garantie du fait personnel** (prévue par **l'article 1628 du CC** qui est un article impératif) qui prévoit une garantie du fait personnel perpétuel, il n'y a pas de délai.

Elle garantit que le vendeur garantit l'acheteur des troubles de droit, qui seraient du fait du vendeur. Par exemple, un vendeur qui a vendu un immeuble et il était dit que cet immeuble était libre de droit et que le vendeur arrive avec un contrat de bail et il va opposer sa position de locataire le droit de rester dans l'immeuble. C'est un trouble de droit. C'est un titre qui diminue la valeur de la propriété de l'acheteur

Attention, si ce droit personnel a été signalé à l'acheteur avant la vente et qu'il était compris dans la vente, il n'y a pas de problème.

Garantie du trouble des faits, c'est un comportement et oui il doit garantir cela. Par exemple, un vendeur d'un appartement qui vend un appartement et vous vendeur vous arrivez tout les jours pour lui demander si l'appartement lui plaît. C'est un comportement qui garantit un trouble de fait, et le vendeur doit le garantir

- **le vendeur doit il garantir le fait des tiers**, ça dépend si c'est un trouble de droit il doit le garantir, mais attention ce n'est que supplétif si rien n'est prévu dans le contrat le vendeur doit garantir l'arrivée d'un tiers qui pourrait venir troubler à cela.

Garantie du trouble des faits, tout les jours un voisin vient toquer à la porte et le vendeur n'est pas sensé garantir cela, sauf si il a un lien avec (mère, fils..), mais si c'est un vrai tiers qui n'est pas affilié au tiers le vendeur ne peut pas garantir ce comportement.

Quelles sont les effets de la garantie ?

Prévue par **les article 1630 et suivants du code civil**,

On prévoit une indemnisation et on prévoit par principe des dommages et intérêts et ensuite on va prévoir selon le choix de l'acheteur une résolution du contrat. Ou alors on continue la vente mais on diminue le prix, donc il y' a un remboursement partiel du prix en plus des dommages et intérêts.

Garantie contre les vices cachés

Le vendeur est garant des éventuels vices cachés qui viennent diminuer la chose, la garantie des vices cachés elle pose non pas sur la possession de la chose elle concerne son bon usage, le fait que l'acheteur qui a été mis en possession de la chose puisse maintenant l'utiliser comme il a prévu de le faire comme il est d'usage, attendu de le faire.

Le vice c'est ce défaut (pejus) qui rends l'usage impropre que ce qui était prévu, ou que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, c'est un défaut qui diminue l'utilité de la chose.

Cet usage dont on parle est un usage normal, habituel, c'est une notion objectif et non pas subjectif. Si on avait prévu pour la chose une chose un peu anormale alors on tombe du côté de la chose

conforme.

La garantie du parlementaire porte uniquement sur les vices cachés, parce que l'acceptation du contrat purge la question des vices apparents. Par contre, les vices cachés ne sont pas purgés par l'acheteur et ils sont à la garantie du vendeur parce que c'est lui qui est présumée être la personne la mieux placée pour connaître l'existence de la chose cachée.

Le vice cachée ce n'est pas le vice dissimulé c'est juste que l'acheteur ne l'a pas vu.
Le vendeur lui est garant de la chose, donc qu'il l'ait vu ou pas il sera considéré comme fautif.
Même s'il est de bonne foi, il est garant, on ne mettra pas sur sa tête des dommages et intérêts dans ce cas là.

Le vice caché c'est celui que l'acheteur normalement diligent ne pouvait pas voir. Le caractère caché du vice s'apprécie en la personne de l'acheteur, c'est une appréciation in concreto (subjectif) cela signifie que par exemple quand on vend une voiture à un particulier qui n'a aucune connaissance de la mécanique on va considérer que beaucoup de vices lui sont cachés contrairement à un professionnel (un garagiste) est sensé lui repérer les défauts.

Comment on fait lorsqu'il y a eu une successions de vente ?

La caractère cachée du vice s'apprécie en la personne de l'acheteur intermédiaire, donc au premier acheteur pour apprécier s'il y a eu vice caché et pas en la question de l'acheteur final.

Il existe un régime légal qui impose au vendeur cette garantie contre les vices cachés mais ce régime légale n'est que supplétif, donc on rencontre assez fréquemment des régimes conventionnels.

Le régime légal est relativement simple, on considère qu'il y a un délai de prescription de 2ans et il y'a des sanctions objectives prévues (alternatif ou l'acheteur peut choisir l'action rédhibitoire et il va demander la résolution du contrat, cela &équivaut à une résolution rétroactif prévue par l'**article 1644 du CC** mais il peut choisir l'article estimatoire, le choix de l'acheteur s'impose au juge,)

Puis il y'a des aménagements conventionnels et des exceptions :

- les ventes forcées, les ventes faite par autorité de justice ne sont pas soumise au vice caché de la chose, **prévue par l'article 1449 du CC**. Le vendeur dans les ventes forcées n'est pas garant des vices cachées
- dans le code rural, la vente d'animaux domestiques n'est pas soumise à la vente de vice cachées (vente d'équidés, par exemple)

Les parties peuvent prévoir une autre forme de garantie :

Les clauses élusifs de garantie, cela est possible uniquement si le vendeur est de bonne foi cad uniquement pour les vices cachées qui étaient effectivement inconnues du vendeur. (**article 1643 du code civil** qui prévoit cette possibilité).

Cela signifie que le vendeur professionnel est forcément considéré comme de mauvaise foi et il ne peut pas implorer cette clause.

Une **clause d'extension de garantie**, on peut accroître la garantie. Le vendeur peut s'obliger à plus et garantir plus ou plus longtemps.

Attention cependant aux fausses clauses d'extension de garantie, les conditions plus drastiques ne peuvent être valables que après le délai de la prescription. Il y'a une réglkementation assez précise

de ces garanties commerciales dans le code de la consommation (**articles L217 et suivants du code de la consommation**)

B – Les obligations de l'acheteur

1) Payer le prix

L'article 1651 du CC qui prévoit cette obligation, il nous dit que le prix ,n'est exigible qu'au moment de la délivrance. Cette règle elle apparaît difficilement compatible avec **l'article 1612 du code civil**. Sois l'un soit l'autre va agir, le vendeur peut agir en résolution du contrat.

En matière de vente commerciale, l'usage est de prévoir quasi systématiquement des délais de paiement (30jours à date de délivrance de la facture), elle a commencé à devenir pour certains secteurs de véritables dérapages.

Il faut pas réclamer de manière abusif des délais de paiement. Le délai a fixé des délais maximums, même si les parties sont d'accord elles doivent tenir à ces délais de paiement maximum.

Il faut expliquer ce qu'implique l'obligation de payer le prix ? Ce qui impose de payer le prix et les accessoires (**article 1593 du CC**), étant précise elle n'est que supplétif et les parties peuvent prévoir que les accessoires à prix de vente, et sont par exemple assumés par le vendeur à titre de faveur commerciale.

Si rien n'est prévu c'est l'acheteur qui doit supporter les accessoires du prix.

Où se passe le paiement du prix ? selon **l'article 1651 du CC**, le paiement se fait au lieu où doit se faire la délivrance et si rien n'est prévu la délivrance se fait au domicile du vendeur. C'est une disposition supplétif là encore.

2) Retirer la chose

L'acheteur doit retirer la chose. La délivrance ce n'est pas une livraison et c'est à l'acheteur d'aller chercher la chose et doit aller retirer la chose. Les frais et accessoires de la chose sont aux frais de l'acheteur (c'est supplétif).

Imaginons la chose dans laquelle l'acheteur refuse de retirer la chose ? Si la chose est conforme il a l'obligation de la refuser, pour la refuser faut qu'il ait un motif juste et véritable (la non conformité). En matière de vente de meubles, la situation est tellement fréquente qu'on a permis aux vendeur un mécanisme de déstockage (**article 1657 du CC**) et de vider leur stock à partir d'un délai de retraitement qui est prévu dans le contrat et si ce délai de retraitement est passé ils ont la possibilité de se débarrasser du bien (soit le revendre, soit le détruire, car le bien est redevenu leur propriété)

CHAPITRE 2 – LES AUTRES CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ

A coté du contrat de vente, il existe des contrats translatifs de propriété et il en existe deux catégories :

- les contrats qui assurent un transfert définitif de propriété de la chose (section 1)
- les contrats qui assurent un transfert temporaire de la propriété de la chose (section 2)

Section 1 – Les contrats assurant un transfert définitif de propriété de la chose

§ 1 – Le transfert immédiat

A – Le contrat d'échange

Le contrat d'échange est comme un dérivé du contrat de vente, sur le plan historique c'est totalement vraie. Le contrat d'échange est historiquement le premier des contrats. La première forme d'échange économique c'est l'échange.

L'échange c'est une vente un peu fruste, il n'y a pas de monnaie ni d'argent dedans, c'est le troc. C'est un mode de circulation des richesses vraiment primitif et archaïque et c'est encore très utilisé dans les grands secteurs d'affaires (par exemple, le commerce international qui comprends beaucoup de cession de créance contre un immeuble, l'échange de droits sociaux en matière de droit des sociétés, le commerce de monnaie, les swaps et on joue sur les taux d'intérêt)

Le problème de disparité de change dans les monnaies, le problème d'embargos de monnaie. L'échange c'est très archaïque mais très utilisé dans le commerce international (la compensation industrielle). L'échange c'est un contrat d'aujourd'hui.

1 – Définition et qualification du contrat d'échange

L'échange c'est un contrat synallagmatique (principe de troc) et dans le contrat commutatif. C'est pas parce qu'il y a pas de prix que ce n'est pas un contrat onéreux parce qu'il y a une évaluation.

L'article 1702 du CC 'l'échange c'est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose ou une autre'. On pourrait dire qu'au regard de cette définition que l'échange n'est qu'une sorte de vente dans lequel il y a un transfert de propriété, on pourrait même dire qu'il y a deux ventes. Ici on a deux transferts de propriété mais sans la présence de prix.

Ça permet de le distinguer entre la vente et l'échange. Il peut y avoir deux ventes et avec les deux mêmes parties. Dès lors qu'il n'y a pas de prix il y a pas de vente.

La dation en paiement c'est le fait de régler un prix, c'est-à-dire d'exécuter une obligation au prix autrement que par une somme d'argent, mais quand on a une dation en paiement on a eu un prix, c'était une vente au départ parce qu'il y avait un prix.

Le cas où il y a un échange entre deux choses qui n'ont pas la même valeur et où on prévoit une soulte, si en revanche la soulte est inférieure à la valeur de la vente, alors on a un simple échange et non plus une vente.

Y a-t-il des enjeux entre la vente et l'échange ? Pas beaucoup, le régime juridique de l'échange est calquée sur celui de la vente. Mais il y a des petites différences de régimes et de qualifications.

2 – Régime juridique du contrat d'échange

Il est gouverné essentiellement par un principe d'assimilation à la vente exprimée par **l'article 1707**

du CC 'toutes les autres règles prescrites pour les contrats de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange'

Quelles sont les règles qui sont spécifiques ? On peut dire que les règles qui concernent les consentement (rencontre capacité..) et celles qui concernent l'objet et les garanties (éviction, vice cachée..) sont celle de la vente. En revanche, tout ce qui concerne le prix, ou tout ce qui concerne la préemption sont des règles spéciales au contrat d'échange.

En matière de consentement, l'échange fonctionne comme dans la vente → solo consensus
Dans certains cas on peut avoir des échanges forcés du fait de la loi, notamment en matière rural.
On peut avoir des hypothèses d'échanges forcés conventionnels, des échanges de titre par exemple qui sont forcés lorsque les échanges arrivent.

La question des garanties

Les deux contractants se transfèrent la propriété et se doivent une garantie de vice caché, d'éviction. Quand il y a une éviction, l'un des co permutants à le choix de continuer à conclure ou le choix de rendre la chose et donc de mettre fin au contrat d'échange.

La question de la résolution

Ce sont les sanctions de droit commun qui sont prévues et la possibilité pour chacun des co permutants d'agir en résolution du contrat d'échange. Dans le mesure où c'est un contrat synallagmatique il y a l'exception du contrat contracté qui joue (**article 1704 du CC**)

La question de la lésion

Normalement en matière de vente, il y' a cette question de lésion qui est posée avec la possibilité de contre carier un déséquilibre énorme, en matière d'échange cela n'est pas possible parce qu'il n y a pas de prix. La lésion c'est une technique juridique qui n'appartient qu' s'il y a un prix (**article 1706 du CC**)

Attention cependant, **la question du droit de préemption ou du droit de préférence** du pacte de préférence, il existe la possibilité de conclure des pactes de préférence si d'aventure le propriétaire de la chose décide de la vendre il doit la proposer en priorité à tel personne et la vendre à tel personne.

Ces droit de préemptions, ces pactes de préférence ne concernent pas la décision d'échanger.

B – L'apport en nature en société

Le principe de la société c'est que les associés se rassemblent autour d'un table et on met des choses en commun (de l'argent ou des choses), et ils vont créer une personne morale qui va agir (avoir des droits et obligations et exploiter) et on va créer une valeur qu'on va partager (ou une dette).

Un société commence à partir du moment où des personnes se rassemblent et apportent quelque chose au groupe et à la personne morale qui va devenir une entité à part entière. Il y a plusieurs types d'apports (l'apport en numéraire, en industrie, en nature)

L'apport c'est un transfert de propriété, le bien en nature que j'apporte à une société il sors de mon patrimoine pour entrer dans la patrimoine de la société, mais il n'y a pas de prix, ce n'est pas une vente. Il y a une différence de nature entre la vente et l'apport en nature en société (contre des apports, des titres de société..)

Il est prévue par **l'article 1544-3 du CC**, on a une assimilation assez forte avec le contrat de vente, puisque l'apporteur doit la garantie contre le vice caché. Mais ce n'est pas un contrat de vente, si vous avez une clause de préférence ou une clause de société cela ne jouera pas en cas de vente. Comme il n'y a pas de prix, il n'y a pas de révision, il y a un sorte d'aléa qui est pris par l'apporteur. Il n'y a pas de prix pour lésion.

C – La dation en paiement

La dation en paiement est prévue par **l'article 1342-4 du CC**, qui nous dit que le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû, cela peut être une somme d'argent ou autre chose. Quand c'est une somme d'argent on a une vente et un prix payé par autre chose qu'une somme d'argent.

La dation en paiement ce n'est pas une vente, c'est un transfert de propriété. Ce transfert est traité essentiellement avec une assimilation contractante (l'obligation de délivrance et des garanties). En revanche, il n'y a pas de révision puisqu'il n'y a plus de prix.

C'est un contrat qui est un peu extra-ordinaire, on ne fait pas ce qui était prévue à l'origine, on considère que c'est un contrat valable mais pas normal. Il est tout à fait valable on ne peut pas la remettre en cause sauf en cas de procédure de redressement judiciaire (en cas de faillite)

Il y' a un risque pour tout les autres créancier que l'on diminue ' l'assiette ' de son actif, alors la dation en paiement est considéré comme nul en cas de redressement judiciaire.

§ 2 – Le transfert retardé

Les montages qui apportent un plus par rapport à la vente simple, ce plus c'est souvent un transfert de propriété qui est retardé. Pour répondre aux objectifs d'une ou des deux parties. On utilise des prix contractuels pour arriver au final au même résultat qu'une vente, mais de telle sorte qu'il n'intervient pas dès l'origine. Il est repoussée et retardée.

A – Certains contrats de distribution

Qui sont construits sur une architecture inscrit dans le droit commun des contrats aujourd'hui. L'idée est de formaliser une relation d'affaire sur le temps long mais dont on ne connaît pas à l'avance le volume, le rythme, l'exemple type est la fourniture d'éléments.

Cette question de la quantité qu'on devra déterminer au fur et à mesure mais on est d'accord pour faire affaire. On peut faire un contrat cadre pour gérer tout ce qui est prévu à l'avance et on se laisse la possibilité de fermer en un clin d'œil le contrat.

B – Les contrats de location-vente et location-accession

Encore appelés les '**leasing**' une pratique contractuelle qui adjoint deux briques (la vente et le bail). En réalité cette adjonction participe à une opération économique qui s'apparente à une opération de crédit. Parce qu'on va associer un bail à une vente de manière à permettre à une personne d'utiliser ce dont elle a besoin mais de faire en sorte que les sommes pour ces utilisations successives ne soient pas totalement perdues et participent d'une sorte de capitalisation.

Ces loyers vont s'accumuler et se capitaliser pour faire en sorte qu'au bout d'un certain moment on puisse acquérir le bien qu'on utilise déjà mais pour une somme qui tient compte de ce qu'on a déjà payé comme redevance/ loyer.

Cela est bien quand on est désireux d'acquérir immédiatement la chose, mais quand on veut se laisser un peu le choix, le temps on a un moyen un petit peu différent et qui revient économiquement au même résultat : **la location-vente**, on est pas obligé d'acheter à la fin, et tant que le prix total n'est pas payé celui qui prête de l'argent il reste propriétaire de la chose et il a la chose comme garantie de paiement.

On peut avoir une vente par une propriété retardée par une clause pénale, la vente on lui assortit une condition, s'agissant du transfert de propriété et de différents termes pour échelonner le paiement. Une vente conditionnée et à terme.

On peut aussi faire un bail assorti d'une promesse unilatérale de vente, au bout d'un certain temps le locataire peut soit lever l'option et devenir acquéreur de la chose ou soit abandonner pour ne pas avoir à payer le solde du prix.

On estime que l'opération est avant tout une opération de crédit et comme un prêt. Le code de la consommation le traite comme cela, et avec des mesures pour protéger le consommateur.

Cela peut marcher autant pour des biens meubles, qu'immeubles. Il ne faut pas confondre cette opération d'opération vente avec le 'leasback', une opération qu'on pourrait appeler la cession-bail qui est beaucoup plus utilisé par les entreprises qui ont besoin de trésorerie mais elles n'ont rien d'autre à offrir en échange que leur bien immobilier et c'est leur seule garantie.

Elles peuvent mettre cet entrepôt sous hypothèque, ou une autre formule ' **le leasback**' on va vendre l'entrepôt à la banque, qui est devenu propriétaire de l'entrepôt va vous le louer et vous faire payer des loyers et associer cette vente avec des promesses unilatérales de ventes pour qu'au bout de certaines années vous rachetiez l'entrepôt en payant un prix résiduel. On mobilise une de ses valeurs pour obtenir de la trésorerie (ça se fait avec une vente, un bail associé à des promesses de ventes et d'achat)

On a le même type de schéma que la location-accession, avec un bien d'habitation qui est à acquérir pour devenir propriétaire d'un bien d'habitation, soit on paye directement soit on emprunte ensuite, on paie et on rembourse, soit on fait un contrat de location-accession, c'est-à-dire qu'on paie le loyer puis au bout d'un certain temps on peut devenir propriétaire (cela est contrôlée depuis **une loi de 1804** pour protéger l'acquéreur et on demande à ce que le contrat soit passée sous la forme authentique comme un contrat immobilier)

C – Le contrat de crédit-bail

Un contrat qui est très fréquemment utilisé dans le monde des affaires, qu'il a été intégrée dans la loi (dans le code monétaire et financiers aujourd'hui), on est sur un contrat commercial et très pratiquée qui permet pour les entreprises de financer aussi bien du matériels et de l'outillage que de l'acquisition de fond de commerce, ou d'immeuble.

C'est une opération de crédit, donc il ne peut être conclu que par un établissement de crédit (une banque)

Un commerçant qui a besoin d'un matériel et qui n'a pas d'argent pour l'acheter directement et qui a la solution pour faire un prêt, c'est le système du crédit-bail ou le commerçant demande à la banque d'acheter le matériel, la banque devient donc propriétaire d'un bien qui lui a été désignée par son client et elle loue ce bien à son client et au bout d'un certain temps le client a la possibilité d'acheter

le bien et d'en devenir propriétaire en payant le prix résiduel.

On a un mandat, le commerçant donne mandat à la banque pour acheter un bien. On a l'achat, la location, la promesse unilatérale d'achat puis un transfert de propriété qui a été retardée (**L300-7 et suivants du code monétaire**). C'est une opération tripartite, car rentre dans l'opération le premier vendeur (le fabricant de l'outillage par exemple)

Section 2 – Les contrats assurant un transfert temporaire de la propriété de la chose

Le droit de propriété (**article 544 du code civil**) a la particularité d'être perpétuelle et le plus absolue qu'il soit. On peut faire ce qu'on veut avec sa chose, on l'utilise ou non, on le vend, on le donne, on le garde et on peut même le détruire.

Le propriétaire détient trois pouvoirs : **l'usus, le fructus et l'abusus**.

Comment organiser un droit de propriété qui est que temporaire ? Il y a des opérations qui vont organiser cela

§ 1 – Le bail emphytéotique

Il font sortir le bien du patrimoine, parce qu'ils sont loin et qu'on doit juger qu'il y a eu comme une fiction. Ils sont prévus par les **articles L441-1 du code rural et de la pêche maritime**.

Il y en a plusieurs types, mais c'est un contrat qui porte nécessairement sur un immeuble et qui assure à une personne qu'on appelle l'emphytéote (qui est le locataire), un droit réel et non pas un droit personnel. C'est-à-dire un droit sur la chose dont il va en voir la maîtrise en contrepartie d'une redevance qu'on appelle le 'canon', généralement modique parce que le but est d'encourager l'emphytéote à exploiter le bien.

Cette formule, elle est prévue dans le code rural et de la pêche maritime, donc elle concerne principalement les fond ruraux, les champs, fermes et les terrains agricoles qui n'ont de valeur que s'ils sont exploités. Qui perdent leur valeur s'ils ne sont pas exploités.

Le propriétaire a la possibilité de les vendre tant qu'ils ont encore de la valeur, et peut être qu'il veut les garder (un mineur qui veut l'exploiter à sa majorité par exemple). Exploiter un fond rural coûte énormément (acheter des graines, couper le foin, payer des outils agricoles...)

Le moyen est le bail emphytéotique c'est-à-dire un bail avec un moyen modérée et avec une durée longue qui permettent à celui qui a investi (le locataire) de rentrer dans ces investissements et de profiter d'un retour sur ces investissements. Sauf que cette durée longue entraîne des questions sur les réparations, la responsabilité...

Il n'y a plus de risque sur le propriétaire, le locataire est devenu propriétaire pendant tout le temps de l'opération et on en a fait un bail emphytéotique. C'est la chose de l'emphytéote et c'est sa chose. C'est donc un acte de disposition, un acte qui obéit aux règles de la publicité foncière , c'est un contrat qui donne au locataire tout les droits du propriétaire (les droits d'accessions devenir propriétaire de tout ce qui se colle à votre terrain , profiter des servitudes qui lui permettent de désenclaver son fond, par exemple)

L'emphytéote a tout les droits d'un propriétaire, il peut hypothéquer son droit. Sauf qu'il n'est pas un

propriétaire définitif, à la fin du bail il doit rendre la chose et la chose revient dans le patrimoine du bailleur avec toutes les améliorations qu'il y a eu sur la chose, il devra y avoir restitution.

La durée minimum c'est 18ans et la durée maximum 99ans, c'est sensé être conclu à titre onéreux même si le canon est modique. Ça transmet un droit réel donc le propriétaire d'origine il doit des garanties comme le vendeur (contre l'éviction et conte le vice caché)

§ 2 – Le bail à construction et le bail à réhabilitation

On est dans le monde de l'habitation et de la construction (**L241-1 et suivants du code de construction et de l'habitation**), imaginons que vous soyez propriétaire d'un terrain, et pas d'argent pour construire un immeuble ou réhabiliter l'immeuble déjà construit. Vous pouvez emprunter de l'argent.

On peut trouver un financer et louer la construction et c'est lui qui va faire l'investissement. Et lui laisser le temps de profiter de son investissement par un bail long, suffisamment long pour que la somme investit dans la construction puisse être amortie.

Comme c'est un bail long, il va falloir dépasser la règle basique du bail (mise à disposition, droit personnel) et on va entrer dans un mécanisme spécial.

Le bénéficiaire du bail à habilitation, obtient un droit réel (il va profiter de l'accession, d'en tirer des bénéfices et à la fin du contrat restituer la chose tel qu'il a été amélioré)

La durée de ce contrat est d'un minimum de 18 ans avec un maximum de 99ans.

On a un transfert de propriété qui se solde par une restitution

§ 3 – Fiducie et autres opérations financières

La fiducie c'est un truc relativement nouveau dans le droit français, on le retrouve dans **l'article 2011 du code civil**, c'est un contrat nommé et reconnu par le code civil désormais et qui concerne 3 personnes :

- **le constituant**
- **le fiduciaire**
- **le bénéficiaire**

Un contrat par lequel le constituant transfère au fiduciaire la propriété de tout ou partie des biens qu'il possède, avec à charge pour ce fiduciaire d'agir dans un but déterminer qui est fixée par le constituant au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires.

C'est un contrat récemment intégrée dans le droit français sur le modèle du droit américain, le modèle du ' trust', il y a un acclimatation faite en 2007 entre ces deux modèles. L'idée est original pour le droit français car on a crée un patrimoine distinct dite affectée : le patrimoine de la fiducie.

Le fiduciaire se retrouve à la tête de son patrimoine, plus celui de la fiducie, celui que l'on a confiée. Ce qui est une vraie nouveauté, qui a bousculée les théories des civilistes.

Il a d'un coté des actifs et passifs à lui et d'autres actifs et passifs mais qu'il est sensé gérer mais qui ne sont pas à lui.

Il va administrer ces deux patrimoines l'un pour son compte et l'autre pour une autre personne.

A – La fiducie

La formation du contrat de fiducie

Le régime prévue par **l'article 2011 du CC** est assez strict :

- il doit être **conclu par écrit**
- doit contenir des **mentions obligatoires** (défini à **l'article 2018 du CC**)
- qui doit être **selon les cas conclus par actes notariés** (un transfert qui porte sur des biens dépendant d'une communauté entre époux, ou sur des biens dit indivi c'est-à-dire frappée d'une indivision, comme une copropriété)
- qu'on soit une **personne physique ou morale**
- dans le cas d'une **gestion de patrimoines**
- Par contre, on ne peut pas utiliser la fiducie dans le cas d'une transmission patrimoine
- les parties ont malgré les formalités une certaine liberté concernant la durée de la formation (elle ne doit pas dépasser 99ans)

Au delà de quelques impératives on a un régime de relatif liberté. C'est un contrat original et dangereux. Il y' a un **enregistrement qui se fait au service des impôts**, car on veut donner une date certaine. Si par hasard il y a des immeubles, il faut en plus de ça une **publicité foncière**.

Les effets du contrat de fiducie

La question des pouvoirs et des missions du fiduciaire doivent être clairement définies. Étant précisé que de manière générale **l'article 2011 du CC** 'il doit agir au compte et au bénéfice du bénéficiaire', Le bénéficiaire peut être le constituant, le fiduciaire lui même ou un tiers, si c'est un tiers il faut faire attention que la fiducie ne soit pas prévue à titre libérale. Pour que le bénéficiaire soit un tiers il faut qu'il ait rendu des services en corrélation avec la valeur du patrimoine fiduciaire, au constituant,

Le fiduciaire pour réaliser ses missions il est astreint à des obligations comptables rigoureuses, c'est une gestion qui est exigée de lui. Il doit donc tenir et rendre des comptes, il a des pouvoirs de gestion au regard des tiers il est présumée avoir les pouvoirs les plus étendues, mais les pouvoirs réelles qu'il a sont déterminées par le contrat de fiducie. Donc au regard du constituant ou d'un éventuel tiers il a des pouvoirs limités par le contrat de fiducie.

S'il doit répondre de ses actes qui outrepassent ses pouvoirs, il répondra de ses fautes sur son propre patrimoine.

→ Cet existence d'un patrimoine d'affectation

Ils sont affectés mais sans la création d'une personne morale. C'est un patrimoine assez spécial qui pose des problèmes, imaginons que le fiduciaire ait des créanciers qui veulent se saisir du patrimoine du fiduciaire, **ont ils le droit de saisir le patrimoine affectée ?**

Les créanciers personnels du fiduciaire ne peuvent pas saisir le patrimoine affectée, ce sont des patrimoines distincts. Les créanciers du constituant ne peuvent pas saisir le patrimoine personnel du fiduciaire. Les créanciers du bénéficiaire doivent tant que la fiducie dure se cantonner au patrimoine du bénéficiaire tel qu'il est.

La question des créanciers du constituant qui vont saisir le patrimoine affectée mais qui n'y trouvent pas suffisamment de biens, peuvent ils se retourner contre le patrimoine personnel du constituant ? Oui, ils peuvent chercher les deux patrimoines, car cela est reliée à la même personne.

Il y' a un moyen d'éviter cela, c'est de prévoir des clauses spéciales et de les faire accepter au créancier du constituant (pas obligatoire pour le créancier), et dire que les droits de poursuites ne pourra s'effectuer que sur le patrimoine restant du constituant.

Ils peuvent rester dans la possession du constituant, ce patrimoine affectée. Il a la possibilité d'en encore les utiliser. On distingue la jouissance de la propriété.

→ Cela se termine quand ?

Il prend fin pour différentes causes :

- en cas de décès du constituant (personne physique)
- à l'arrivée du terme
- avant le terme si le but poursuivi a été atteint
- cela prends fin lorsque tout les fiduciaires renoncent à la fiducie, on peut quand même prévoir dans le contrat de fiducie une clause de continuation
- la liquidation du fiduciaire (liquidation judiciaire), auquel on associe l'hypothèse ou le fiduciaire fait l'objet d'une dissolution (dans la mesure où c'est une personne morale)

On assimile aussi cette hypothèse à l'absorption du fiduciaire (institut personæ),on met fin lorsque le fiduciaire à l'interdiction de gérer, où lorsqu'il est avocat s'il perd sa qualité d'avocat il ne pourra plus être fiduciaire (le fait qu'il soit avocat est la cause de pourquoi il a été nommé fiduciaire)

Quand il y' a la fin du contrat de fiducie il peut y avoir différentes hypothèses :

- le but poursuivi est atteint alors le bénéficiaire aura les effets de cette fiducie qui lui seront dues.
- le décès du constituant donc les biens reviennent au constituant donc à la succession du constituant

B – La convention de portage

Une technique utilisée en droit des propriété, par exemple, un opérateur a envie d'être propriétaire d'une action en société alors il va s'adresser à un opérateur spécialisée (opérateur de crédit) en lui demandant d'acquérir les opérations pour lui en donner la possibilité d'en devenir propriétaire lui-même.

La situation de quelqu'un qui est un vendeur par exemple une personne qui devient ministre et qui ne peut plus gérer une entreprise il doit la céder le plus rapidement possible, on peut la céder à un opérateur de crédit qui est chargée de vendre les actions à une autre personne.

Il y a tout un mécanisme qui doit se mettre en place :

- il faut donner un mandat à l'établissement de crédit-bail
- il y' a des cessions
- des promesses (unilatérales de ventes, d'achats..)
- une ingénierie contractuelle a mettre en place, car on a un établissement crédit qui n'as pas envie d'assumer les risques de la propriété (avec notamment les titres de société) Il va falloir organiser les risques de la chose.

On peut utiliser la convention de portage :

- pour les gages
- la convention de croupier (quelqu'un qui se porte acquéreur des biens en étant totalement opaque sur la destination du bien à, cela a des inconvénients car c'est une simulation.

TITRE II – LES CONTRATS PORTANT SUR L'USAGE D'UN BIEN

L'objectif est d'utiliser le bien : **le bail et le prêt** portent spécifiquement sur l'usage d'un bien, ils ont comme bien commun d'entraîner une mise à disposition temporaire, c'est-à-dire il y a une obligation de restitution.. Cette obligation de restitution a été laissée de côté par les rédacteurs du code civil, cette obligation de restitution était connue en droit commun, pourquoi n'ont-ils pas repris cette obligation du droit romain ?

Il n'ont pas fait un régime juridique de mise à disposition, et pour autant c'est au cœur de ce contrat de bail et de prêt.

Par exemple, le contrat de dépôt, il y a une obligation de restitution dans ce contrat le dépositaire doit rendre le bien qu'il a entre les mains, sauf que pendant le dépôt il n'y a pas d'obligation de mise à disposition. Le dépositaire n'est pas sensé utiliser la chose mais simplement la garder. Le propriétaire n'a pas à faire des efforts pour que le dépositaire puisse l'utiliser. On peut rajouter dans le contrat de dépôt quelques obligations ou permissions qui peuvent faire ressembler le contrat de dépôt à un contrat de bail ou de prêt.

CHAPITRE 1 – LE BAIL

Définition du contrat de bail

Définit dans **le code civil par l'article 1709** ' le louage de choses', en nous disant que le louage de choses ' est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à louer une chose à une personne pour un certain temps et que cette personne s'oblige à lui payer'

Cette mise à disposition est temporaire et onéreux. C'est-à-dire une somme d'argent est indiquée dans le contrat, il y a dans ce contrat un droit personnel du locataire, contre le bailleur, il a le droit d'exiger de profiter de l'existence du bien. C'est un droit personnel de jouissance qu'il obtient parce qu'il paye un prix. Ce n'est pas un transfert de propriété.

Utiliser les termes bailleurs ou loueur est plus appropriée, en fait on a le preneur à bail. Quand le bien qui est loué est un bien incorporel on parle de licence (portant sur un bien incorporel, licence de marque ou de brevet).

Qualification du contrat de bail

Un droit personnel et temporel, qui donne droit à la jouissance du bien. Il y a une obligation de restitution, certes il y a un prix comme dans le contrat de bien mais ce n'est pas cela qui fait l'obligation caractéristique du contrat (l'obligation de mise à disposition, dans le contrat de vente).

Certains contrats de bail sont tellement long qu'ils donnent naissance à un contrat de vente (bail emphytéotique..).

Dans le bail on a quelqu'un qui jouit d'une chose mais attention cela peut ressembler au contrat de vente, mais dans le bail l'utilisation de la chose est limitée, il ne peut pas en faire n'importe quoi.

Notamment, il ne peut pas détruire le bien, il a les limites du contrat, l'utilisation du bien est par principe limité.

Attention, il peut y avoir des limitations conventionnelles, mais par principe il doit y avoir un véritable, jouissance de la chose, il faut quand même que le preneur à bail puisse utiliser la chose et en percevoir les fruits. Si les droits de jouissance sont à ce point limités ce ne sera pas un bail.

La jouissance du bien est un élément de qualification ou de disqualification, on fait comme ça la différence entre un bail et un contrat de coffre fort (lingots, documents, bijoux dans le coffre fort de la banque) . On a pas une jouissance de coffre fort, donc ce n'est pas un contrat de bail.

Le bail c'est un contrat qui doit être onéreux. Il faut donc un prix, il y' a alors des contrats qui permettent la mise d'un bien avec la mise à disposition. Un bail gratuit n'existe pas. L'absence de prix c'est un élément de disqualification de la notion de bail.

Si la contrepartie n'est pas financière ce n'est pas un bail, il y' a des contrat qui s'appellent bail mais qui n'en sont pas (le bail à nourriture, ce n'est pas un bail au sens du code civil, c'est un contrat dans lequel la jouissance d'un immeuble est concédée en échange d'un engagement de loger, nourrir entretenir et soigner le bailleur, c'est un contrat or cale)

Avec l'apport en jouissance, on peut faire l'apport en propriété mais aussi en jouissance, le bien continue de m'appartenir mais c'est la propriété qui en jouit. C'est pas un bail, la contrepartie n'est pas un prix, un loyer, la contrepartie c'est un titre de société (des actions..).

Attention dans certains baux il peut y avoir certaines exceptions, par exemple le météage et on a une contrepartie qui est payée sous forme de portion de la récolte (cela ne doit pas dépasser 1/3)

Les sources du contrat de bail

Il est traité dans le code civil, ce sont **articles 1713 à 1778 du code civil**. Mais à l'instar de tout les contrats spéciaux du code civil, le contrat de bail connaît une hyper spécialisation. Il y' a des sous catégories de contrats de bail, et une multiplicité de régime interactive, avec des régimes spéciaux qui sont impératifs mais pas dans le code civil.

Ce sont des régimes spéciaux qui concernent les baux les plus importants (par exemple, le bail d'habitation, le bail pour une bien commercial, les biens ruraux, les biens professionnels..)

Le code civil prévoit des règles qui sont par principes supplétives, mais elles ne s'appliquent qu'à certains types de baux, par les baux régis par des régimes spécifiques. Qui eux font l'objet de réglementation spéciale et qui sont en principe impérative.

La en principe ces régimes spéciaux sont quasiment tous impératifs

Section 1 – Le droit commun du bail

Ce contrat là fait l'objet de réglementation hors du code civil.

§ 1 – La formation du bail

Comme n'importe quel contrat il est possible en matière de bail d'utiliser des avants-contrats (promesses, pactes..). Ce qui va nous intéresser ce sont les règles de fond posées par le CC.

A – Les règles de fond

Il faut un objet comme n'importe quel contrat de bail, c'est le principe.

1) L'objet du bail

a) La chose

Le bail peut porter sur toute formes de biens, corporels ou incorporels (**article 1708 du CC**). Il y a des questions qui se posent comme par exemple cette hypothèse de celui qui mettrait en location une chose qui en serait pas la sienne.

Est il possible de passer un bail sur une chose qui n'appartient pas au bailleur ? Oui le contrat de bail ne suppose pas que le bailleur soit propriétaire de la chose, car le bail n'importe par transfert de propriété.

Cela peut poser quelques difficultés dans l'hypothèse ou le bailleur loue le bail et qui voit sa jouissance troublée par le propriétaire du bail. Si le preneur est troublée il peut agir en responsabilité à l'encontre de son bailleurs, c'est une relation avec des obligations personnelles. Le preneur peut se retourner contre le responsable.

Est ce que le bail est opposable au propriétaire ? Non, le bail de la chose d'autrui est inopposable au propriétaire, il a la possibilité d'obtenir l'exclusion du preneur. Mais dans la mesure où le propriétaire n'avait pas autorisé le bailleur à louer le bien et ou il n'est pas d'accord avec le bail.

Deux exceptions peuvent intervenir :

- **une fausse exception**, se rendant compte que son bien est loué il peut toujours le confirmer, le ratifier qui n'aurait pas été de son initiative et il s'interdit d'expulser le preneur.
- **La théorie de l'apparence**, le preneur à la possibilité de rester dans les lieux et de contester l'expulsion, si le bailleurs s'est présenté comme le véritable propriétaire et que toutes les conditions lui ont montré comme étant le véritable propriétaire. (basée sur l'erreur commune, 'erreur cominis facis ut').
Donc on doit tenir compte de l'apparence et pas de la vérité. Dans ce cas la on rend le bail opposable au véritable propriétaire et il y a pour lui une forme de sanction ou quelqu'un s'est présenté à sa place comme propriétaire.

Deuxième problématique liée à la perte de la chose

La chose disparaît et est détruite par cas fortuite, **article 1722 du CC** qui prévoit que ' si pendant la durée du bail la chose fortuite est détruite le bail est résiliée de plein droit, si elle n'est détruite qu'en partie le preneur peut suivant les circonstances demander une diminution du prix ou la résiliation du bail'

Ici on serait plutôt dans le cas d'une caducité parce qu'on a un élément essentiel à la formation de la chose, qui existait au moment de la formation du contrat et qui ensuite disparaît.
Cet article s'applique aux choses corporelles, mais aussi elle peut s'appliquer à des choses incorporelles

b) Le prix

Le prix est un élément de définition et de qualification. Le prix est une somme d'argent.

La question qui se pose est quel prix ? Comment fixe t-on le prix dans un contrat de bail ? Il faut qu'il soit déterminée et peut être déterminable c'est-à-dire en fonction de critère objectifs.

En pratique le loyer est fixée par la convention des parties (pas de contrôle de prix), elles vont généralement avec un forfait qui s'étend par période, on fixe une somme qui ne bouge pas. On peut aussi fixer un loyer variable, qui va varier en fonction de différents critères (qui doivent être fixées au départ de manière identifiable et de manière objectif)

On peut aussi combiner les deux et faire un forfait auquel on applique un variable. Avec deux façons d'appliquer le variable :

- soit c'est supplément qui s'ajoute au forfait
- soit le forfait est lui même variable en fonction d'un index particulier (une clause d'indexation, par exemple l'indice des prix à la consommations, l'indice du coût du blé, l'indice du coût de la construction..)

Le droit français depuis très longtemps impose des conditions sur le choix de l'indexation. Il faut que l'indice choisi soit en rapport avec l'une des partie ou avec l'objet du contrat, si ça n'est pas le cas l'indice est déclarée nul (juste la clause d'indexation, pas le loyer).

2) La durée du bail

Le bail est l'archée type du contrat d'exécution successive. Il faut alors une durée qui peut être très courte, pendant cette durée ce qui compte c'est qu'il ait une jouissance stable. Il faut avoir une certitude que cela ira jusqu'au bout même si la durée est très courte. Le preneur ne doit pas être dans une situation d'instabilité à la merci du bailleur,

Si en revanche le bailleur loue un bien pour 1 an mais qu'au bout de 1 jours, 1 mois, 4 mois.. le bailleur peut venir et lui dire de partir alors il n'y a pas de stabilité donc il manque un élément au contrat de bail et le contrat est alors requalifié (si on juge que la jouissance n'est pas stable)

Si dans le contrat cela est précisé que le bail peut cesser à tout moment, sans instabilité alors ce n'est pas un contrat de bail (la convention d'occupation précaire par exemple, la durée qui est prévue peut s'interrompre à tout moment)

3) La détermination de la durée

Comment on détermine la durée ? Le CC s'agissant cette détermination opère une distinction qui est ancrée dans le droit français, la distinction entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée:

Le contrat à durée déterminée : le CC parle de bail par écrit, cela signifie que dans les obligations du bail il y' a un terme, on va adjoindre aux obligations du bail un terme (un événement futur et certain) Ce terme peut être certain ou incertain.

Il y a toujours la question de la date qui peut être certaine ou incertaine (un événement futur et certain mais dont la date est incertaine, par exemple la mort)

Dans un contrat de bail on peut mettre un terme, qui peut être certain ou incertain selon la volonté des parties.

Le bail cessera le jour où le terme arrive, cela cesse sans qu'il ait besoin de mettre un congé. Il arrive assez fréquemment que malgré l'arrivée du terme, le preneur se maintienne dans les lieux, soit parce que:

- **les parties sont finalement d'accord pour que le preneur reste** (un renouvellement du bail, un nouveau contrat)
- **un accord tacite**, on a pas la certitude du contenu du contenu si ce n'est que le preneur reste dans les lieux, et on considère que le bail continue aux mêmes conditions que l'ancien et le bail devient à durée indéterminée (article 1738 du CC qui prévoit cette situation)
- **un accord express** et généralement les parties prévoient toutes les stipulations (clauses) du contrat
- si le preneur se maintient alors qu'il y a eu congé, alors le preneur occupe le bien sans droit ni titre. On peut forcer la restitution (une expulsion qui s'accompagnera de dommages et intérêts)

Le contrat à durée indéterminée : le CC parle du bail sans écrit et il est prévu que chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatérale discrétionnaire, et chacune des parties peut sortir du bail sans expliquer les motifs de la résiliation, mais ce droit doit respecter certaines conditions dont le pré-avis (qui peut être fixée dans le contrat ou conforme aux usages c'est-à-dire d'une durée raisonnable)

Cette règle est d'ordre public, donc les parties ne peuvent pas la contre-carrer dans le contrat. Si les parties le mettent dans le contrat c'est un motif de nullité absolu du bail et n'importe qui peut demander la nullité du bail.

4) La stabilité de la jouissance

Cette préoccupation de la stabilité de la jouissance est dans le code civil, Par exemple **l'article 1743 du CC** qui dit que ' si le bailleur vend la chose louée l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique dont la date est certaine' c'est-à-dire que le bail est opposable au nouveau locataire.

C'est un c'est-à-dire de cession de contrat prévue par la loi, et légale. Étant précisé que cette cession légale ne s'applique qu'aux locations immobilières (pas aux locations mobilières). Cet article pose les conditions (conditions de formes notamment) ces conditions de formes elles sont là pour éviter le bail anti-daté (fraude) et la jurisprudence assouplit cet article. Ce qui compte c'est de débusquer les fraudes.

Le décès de l'une des parties, n'entraîne pas la fin du contrat de bail (**article 1742 du CC** ' le contrat de louage n'est point fourni par la mort du bailleur ni par celui qui..' le bail tombe dans l'indivision successorale et les héritiers deviennent parties au contrat.

La question du droit au renouvellement dans beaucoup de statuts spéciaux, le preneur dispose d'un droit au renouvellement

B – Les règles de forme

En principe le contrat de bail obéit au principe de consensualisme (principe de droit commun, notamment avec **l'article 1714 du CC** qui dit qu'on peut louer par écrit ou verbalement)

On a la question des baux ruraux, or les règles spéciales ce sont quasiment tout les baux immobiliers.

Article 1715 du CC qui nécessite d'être interprétée, il dit que ' si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution..' On se dit que quand le bail n'a pas d'écrit cela va être très compliqué de le prouver surtout si l'une des parties le nie et surtout si ce bail n'a pas encore reçu d'exécutant. Parce que le code nous dit que la preuve par témoins ne marchera pas. Le seul truc qui marchera c'est le serment.

Cet article a été interprété par la jurisprudence à contrario (contra legge). La jurisprudence considère que dès lors qu'il y a un début d'exécution la preuve d'exécution du bail devient libre. Cette jurisprudence écarte **l'article 1715 du CC** car la preuve du début de l'exécution est elle-même libre (on peut prouver ce début d'exécution par témoignage)

Comment prouver le contenu du contrat de bail? Ce sont les règles de droit commun qui s'y appliquent sauf en ce qui concerne le loyer. Pour la question du loyer c'est **l'article 1716 du CC** qui s'applique,

Selon cet article, il y a un certain nombre de modes de preuves qui sont acceptables :

- **la quittance** (un commencement du contrat de bail par écrit)
- **Pas de quittance** (on demandera un propriétaire et il fera serment)
- Si le locataire dit qu'il ne fait pas confiance au serment, il peut faire **une estimation par un expert**, ce qui veut dire que le juge ne peut pas fixer lui-même le loyer du contrat de bail.

Ce qui veut dire que le juge ne peut pas fixer lui-même le loyer du contrat de bail. L'article 1716 du CC interdit au juge de fixer lui-même le loyer du contrat de bail.

§ 2 – Les effets du bail

A – Les obligations du bailleur

1) Les obligations stricto sensu

Prévues aux **articles 1719 à 1727 du CC**. Toutes les obligations du bailleur s'expliquent par celles qui sont essentielles ou fondamentales de la chose louée, il y a l'obligation de celle d'assurer la jouissance paisible de la chose.

On dit de cette obligation que c'est « l'âme du bail » et le bailleur ne peut pas s'en exonérer, sinon ce n'est pas un bail. Elle n'est pas sans limite et c'est une question très importante, au prétexte de cette obligation il y a des preneurs qui réclament beaucoup de leurs bailleurs.

Par exemple, l'ensemble de désactivation des semaines électriques. Un digicode qui est installée pour entrer dans l'immeuble et qui nécessite de l'électricité et plusieurs des locataires demandent à ce que ce digicode soient remplacé par un système mécanique au moins sur certains jours de la semaine pour des raisons religieuses. La jurisprudence réponds que ,non, le bailleur n'est pas tenu de faire en sorte que le bien loué permette un exercice d'une religion complet

La question ne tient pas qu'au droit du bail, mais aussi aux droits et libertés fondamentaux des personnes physiques (le droit au secret, le droit de ne pas être importuné dans sa vie privée..)on ne peut pas demander à un bailleur de permettre un exercice complet d'une religion sans lui permette de demander à ses locataires quelle est leur religion. On a privilégié le droit à la vie privée.

Le bailleur a une obligation de sécurité qui pèse sur lui, On va s'attarder sur l'obligation de délivrance.

a) L'obligation de délivrance

C'est **l'article 1719 du CC** qui pose le principe et permet la jouissance paisible et pour permettre cela il faut la délivrer. Cet article entend l'obligation de délivrance dans le bail dans la même manière que l'obligation de délivrance dans la vente. C'est une obligation de ne pas empêcher le preneur d'entrer en possession.

Une petite différence posée dans **l'article 1720 du CC** ' le bailleur doit délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce', il va y avoir utilisation par le preneur ce qui n'est pas forcément le cas dans la vente (ce qui compte c'est juste le transfert de propriété).

Cet article 1720 du CC est supplétif, les parties peuvent très bien l'écarter. Cela dit l'article 1720 est supplétif, il peut y avoir des clauses exclusives qui seront interprétées de manière restrictive, donc s'il y a un doute la doute va profiter au preneur.

b) L'obligation d'entretien

Il faut que la jouissance du bien soit paisible, et qu'elle dure tout le long du bail. Or pour ça il faut que la chose soit entretenue d'où l'obligation d'entretien qui pèse sur le bailleur.

Doit-il supporter tout l'entretien nécessaire de la chose ? Le code civil organise une répartition des réparations qui sont nécessaires pour que le bien reste en état d'être utilisé.

Cette répartition est faite par **l'article 1719 et 1720 du CC** ainsi que **l'article 1754 du CC** :

- on a d'un côté les **réparations locatives** (le menu entretien, l'entretien quotidien, de tout les jours, qui est nécessité par l'utilisation quotidienne du bien, qui sont à la charge du preneur
- on a de l'autre côté les **réparations importantes**, qui sont par rapport à la structure du bien, celle là sont à la charge du bailleur

C'est une répartition supplétif, donc les parties peuvent prévoir une autre répartition, les clauses qui organisent une répartition différente sont interprétées de manière respectueuse (dans le sens des intérêts du locataire, protection du locataire et une forme de présomption pèse sur le locataire qui serait la partie faible du contrat de location)

Le bailleur a aussi des garanties, la garantie de vice cachée

2) Les garanties

a) La garantie des vices cachés

L'article 1721 du CC qui prévoit cette garantie, qui dit que les garanties des vices cachés en matière de bail sont pareil que celle dans la vente, à quelques nuances près :

- en matière de bail, l'action en garantie de vice cachée n'est pas enfermée dans un délai de 2ans, elle est enfermée dans le délai de droit commun
- en matière de bail, le vice apparue en cours de vente est pris en compte
- en matière de bail les clauses limitatives sont valables

b) La garantie d'éviction

Le bailleur doit garantir le preneur contre son fait personnel, la garantie du fait personnel du bailleur. Il doit faire en sorte que le preneur ne soit pas gêné dans son utilisation par le comportement du bailleur.

Cela a beaucoup posé de questions s'agissant du bail commercial, lorsqu'un bailleur loue un fond de commerce est ce qu'il peut s'installer pas très loin du local et ouvrir un commerce pour son propre compte ou **est ce que la garantie d'éviction l'empêche de faire ça ? Y aurait il pas une obligation de non concurrence ?**

La jurisprudence considère que non cela n'implique pas une obligation de non concurrence, mais dans les clauses il y' a tout le temps une clause de non concurrence dans les contrats de bail commercial.

Est ce que le bailleur doit garantir le fait du tiers ? Ça dépend des faits du tiers :

- **quand c'est un trouble de droit ?** Un tiers qui débarque avec un titre juridique, oui le bailleur doit garantir les troubles de droit qui seraient le fait des tiers
- **quand c'est un trouble de fait ?** le bailleur n'est pas tenu de garantir le trouble que le tiers apporte de fait par sa jouissance

Cet article est supplétif, et il faut bien s'entendre sur la notion de tiers. Il faut que ce soit un tiers véritable à l'égard du bailleur. Il y a des situations où le tiers n'est pas en situation d'être le vrai tiers à l'égard du bailleur.

Par exemple, un bailleur qui doit propriétaire d'un appartement dans une copropriété, il ne doit pas garantir les faits d'un tiers de l'autre copropriétaire

B – Le statut du preneur

1) Les obligations du preneur

Prévue dans le code civil aux **articles 1728 à 1737 du CC**, ce preneur a des obligations :

- qui visent l'usage de la chose d'autrui
- le preneur doit utiliser cette chose en « bon père de famille » c'est-à-dire sans excès si rien n'est prévu dans le contrat (dans le contrat on peut mettre des clauses liées à l'usage de la chose et qui déterminent l'usage de la chose, par exemple la clause d'habitation bourgeoise dans les baux d'habitation, c'est-à-dire que dans le local qui est loué il faut y habiter par y faire un commerce, ou une activité libérale, ou des clauses à destination commerciales au contraire, ou encore une clause d'habitation personnelle qui est lui considéré comme une atteinte à la vie privée)

Sur le preneur pèse une obligation de restituer la chose en temps voulu, prévue par **l'article 1730 du CC**, c'est une obligation importante qui pèse sur le preneur et sans elle il n'y a pas de contrat de bail. C'est une obligation qui pose des problèmes pratiques : parce qu'on doit restituer la chose qui a été louée, une obligation de conservation (il doit faire les réparations locatives).

Cette obligation de restitution implique cette obligation de conservation qui impose qu'il fasse des séparatives locatives, qui lui interdit de modifier la substance de la chose, une obligation de répondre des dégradations et des pertes liés à l'usage.

Cette obligation de restitution va obliger de faire des états de lieux, à l'entrée c'est-à-dire au début du contrat de bail et au moment de la délivrance et à la sortie c'est-à-dire au moment de la restitution.

Si on ne fait pas d'état de lieu il y' a un situation prévue à **l'article 1730 du CC**, il y' a un présomption qui joue, le preneur est présumée avoir reçue la chose en bon état

En matière incendie il y' a un règle spéciale qui s'applique (prévues aux articles 1733 et 1734 du CC) et qui prévoient 3 cas d'exonérations.

2) Les pouvoirs du preneur

Le preneur à l'obligation de payer le loyer, le bailleur cherche à se prémunir contre les impayées. Il demande un dépôt de garantie (qui est assez fréquemment appelé caution), ce dépôt de garantie est valable par principe.

Pour les baux d'habitation cette pratique est réglementée, il y' a des conditions à respecter : **Cette garantie est t-elle de paiement de loyer ? de bonne restitution du bien ? ou des deux ?**

Il y a fréquemment une caution, c'est-à-dire que le bailleur réclame du locataire de lui procurer une caution, c'est-à-dire de venir avec une autre personne qui va s'engager à payer le loyer si le loyer n'est pas payé par le locataire (c'est un contrat de sûreté) par lequel une tierce personne s'engage à couvrir la dette si la dette n'est pas payée par le débiteur principal.

Section 2 – Les statuts spéciaux

§ 1 - Bail d'habitation

§ 2 - Bail commercial

§ 3 – Bail professionnel

§ 4 – Baux ruraux